Universidad de Costa Rica

Sistema de Estudios de Posgrado

“El daño moral indirecto familiar y social como responsabilidad patrimonial de la Administración”

Trabajo final de investigación aplicada sometido a la consideración de la Comisión del Programa de Posgrado en Derecho para optar al grado y título de Maestría Profesional en Derecho Público

Katherine Tatiana González Coto

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

San José, 2024

AGRADECIMIENTO

A Dios por permitirme concluir con todas las etapas de mi vida al día de hoy.

A mis padres y a mi familia por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad; muchos de mis logros se los debo a ustedes entre los que se incluye este. Me formaron con reglas y con algunas libertades, pero al final de cuentas, me motivaron constantemente para alcanzar mis anhelos.

A mis profesores, por los aprendizajes a lo largo de mi carrera.

HOJA DE APROBACIÓN

Este trabajo final de investigación aplicada fue aceptado por la Comisión del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar al grado y título de Maestría Profesional en Derecho Público.

Dra. Magally Hernández Rodríguez

Representante de la Decana

Sistema de Estudios de Posgrado

Dr. Roberto Garita Navarro

Profesor Guía

Dr. Hubert Fernández Argüello

Lector

Dr. Rafael González Ballar

Lector

Dr. Víctor Orozco Solano

Director Coordinador / Representante

Programa de Posgrado en Derecho

Katherine Tatiana González Coto

Sustentante

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTO.....ii

HOJA DE APROBACIÓN..... **¡Error! Marcador no definido.**

ABSTRACT v

LISTA DE ILUSTRACIONES.....vi

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL DAÑO MORAL INDIRECTO 1

CAPÍTULO II. DAÑO MORAL INDIRECTO FAMILIAR O SOCIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO..... 20

CAPÍTULO III. GUÍA DE ASPECTOS BÁSICOS PROCESALES Y SUSTANCIALES DEL DAÑO MORAL INDIRECTO...... 49

CONCLUSIONES.....55

RECOMENDACIONES 58

BIBLIOGRAFÍA.....60

ABSTRACT

This paper examines the legal framework of indirect moral damage, defined as harm suffered by individuals collaterally affected due to direct damage inflicted upon a third party. The conceptualization of indirect moral damage requires fulfillment of essential parameters: damage must be certain (real and effective, not hypothetical), personal (affecting the claimant directly or indirectly), and both effective and evaluable (susceptible to monetary valuation).

From a subjective perspective, this research delimits the scope of subjects entitled to compensation from the Administration for indirect damages. A critical determinant is the existence of a juridical link between the indirect victim and the direct victim, rather than merely an affective bond. In the family context, this juridical link is established through the legal concept of FAMILY, while in social contexts, it manifests as COLLECTIVE INTEREST.

The analysis distinguishes indirect moral damage from liability for acts of third parties. In the former, there is an expansion of the objective element (the damage itself), extending beyond the original victim to those affected by the ripple effect of the initial harm. This differs significantly from liability for acts of third parties, which typically involves culpa in eligendo or culpa in vigilando, where responsibility shifts based on extension of subjective elements of imputation.

From an objective perspective, the causal nexus in indirect damage cases operates on a second level but remains equally determinant and efficient. The persistence of damage is crucial for compensation claims, as is the principle that compensation for the direct victim does not automatically compensate the indirect victim.

The study also addresses collective moral damage, where harm affects a group sharing common interests. This includes environmental contexts where pollution indirectly disrupts collective well-being, creating liability for damage derived from environmental contamination.

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.1 ……..…….17

Capítulo I. Generalidades del daño moral indirecto

Sección I: Conceptualización y parámetros generales sobre el daño moral indirecto.

- Falta de una delimitación conceptual del daño moral indirecto

En cualquier temática resarcitoria, se deben cumplir ciertos requisitos básicos que se determinaran de seguido:

- Debe ser cierto

El daño es cierto, es decir, es posible constatar la existencia de este de manera cualitativa, a pesar de no ser susceptible la determinación exacta. La certidumbre indica que el daño moral deberá ser real y efectivo, no hipotético ni conjetural. Ahora bien, cabe resaltar que dicha certeza no debe ser absoluta, más si razonable.

- Debe ser personal

En cuanto a la personalidad del daño, se refiere a que sólo la persona que sufre el perjuicio patrimonial o moral de modo directo o indirecto se encuentra en posición de demandar la reparación. Ello significa que el aspecto personal del daño identifica al o a los damnificados como titulares de la acción resarcitoria y así determina su legitimación activa, debidamente cubierta por el ordenamiento jurídico.

- Debe ser efectivo y evaluable

Demas esta señalar, que el daño habrá de ser efectivo y evaluable tal y como lo disponen diversas normas en nuestro ordenamiento jurídico (verbigracia 196 de la LGAP). Lo primero dice de la realidad del daño, es decir, de su efectiva producción. No excluye ello el perjuicio, que, entendido como la pérdida de un beneficio, es futuro pero cierto. A su vez, a de ser evaluable, lo que implica no otra cosa que su susceptible valoración en dinero, todo lo cual implica que la abrumadora mayoría de indemnizaciones en materia de daños se configura como una obligación de valor.

Sección II: Delimitación del daño moral indirecto desde la perspectiva subjetiva

- Concreción en la parte subjetiva afectada

Una vez definido el concepto básico de daño moral indirecto, el cual entendemos como aquella víctima afectada en su entorno jurídico de manera colateral como consecuencia de la existencia de un daño directo a un tercero. Resulta de gran importancia delimitar los sujetos susceptibles de indemnización patrimonial por parte de la Administración[1] a causa de este daño indirecto.

Un factor importante para valorar además de la subsistencia de un daño indirecto es el vínculo que se comparte con dicho damnificado directo. Es decir, el lazo o relación que une a la víctima indirecta con la víctima directa. Es por esto por lo que, si se pretende una indemnización patrimonial por parte de la Administración, el vínculo afectivo no sería la opción más conveniente a diferencia del vínculo ***JURIDICO*** que se encuentra debidamente regulado.

Este vínculo jurídico se toma como un factor genérico, en otras palabras, es un factor indispensable que debe estar presente dentro del daño ocasionado que se alegue, sin embargo, acorde a la situación que se tenga enfrente así se adecuará.

[1] González J. 1996. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Editorial Civitas S.A. Madrid, España. Pág 45.

En el ámbito familiar, el vínculo jurídico, será primordialmente el concepto de ***FAMILIA***, mientras que en el ámbito social[2] sería el ***INTERES COLECTIVO***.

Ahora bien, un aspecto por esclarecer: ¿Por qué el damnificado o víctima no puede ser calificado como un tercero dentro del evento dañoso? Como ya se explicó líneas atrás, un damnificado es aquel que se ve afectado personalmente por el suceso mientras que el tercero en un sentido amplio es toda persona que no figura como víctima o victimario en un suceso y, por tanto, es completamente ajena e indiferente a lo sucedido. Es por esto que las figuras jurídicas no son coincidentes y por tanto no es posible encajar la víctima indirecta[3] como un simple tercero.

DIFERENCIA CON LA RESPONSABILIDAD POR HECHO DE UN TERCERO.

En la responsabilidad por lesión refleja o consecuencial, se compromete el patrimonio del responsable frente a esa víctima primaria o inmediata atendiendo a los criterios de imputación dispuestos como necesarios por el ordenamiento jurídico en la materia específica respectiva y en consideración a la relación jurídica subyacente de cada circunstancia. Así, en algunos casos será, el dolo o la culpa grave; o bien el funcionamiento anormal, normal, lícito o ilícito; e incluso atendiendo a criterios propios de la responsabilidad objetiva (cuando en verdad exista), como es el supuesto de la responsabilidad patrimonial en materia de consumo.

Pero este criterio de imputación no se configura como requisito (al menos imprescindible), respecto del tercero (víctima secundaria o mediata), pues está claro, que basta la antijuricidad de la conducta de quien genera el daño sobre la víctima primaria (ya sea de base o resultado), para que la obligación reparatoria cubra, de igual forma, la lesión de la víctima mediata (tercero).

---

[2] Aguirre Garabito. A. Sibaja López. I. 2010. Lineamientos Para La Comprensión Del Daño Social Y Sus Posibles Aplicaciones En El Derecho Costarricense. Licenciatura. Universidad De Costa Rica.

[3] Zavala de González M. 2009. Tratado de Daños a las personas resarcimiento del daño moral. Editorial Astrea. Argentina. Pág 266

Dicho de otro modo, aquí no opera una extensión del criterio de imputación, que haga imprescindible encontrar el dolo, la culpa, la conducta ilícita o anormal del productor del daño en relación con el tercero (víctima indirecta).

La razón es sencilla, el responsable no despliega una acción u omisión con incidencia directa e inmediata hacia quien figura como tercero. Es preciso recordar (a riesgo de ser cansina), que la persona que figura como víctima indirecta, lo es como reflejo de la lesión causada a la que se presenta como inmediata o directa.

Esto es muy distinto de lo que ocurre con la responsabilidad patrimonial por hecho de un tercero, normalmente encausada a través de la culpa in eligendo o culpa in vigilando.

En este último supuesto es muy distinto, pues la persona asume la responsabilidad no por una acción dañosa propia, sino por el hecho, acto u omisión cometido por un tercero, distinto de aquél que produjo directamente la lesión, atendiendo, no a un criterio objetivo (expansión del daño), sino por el contrario, por la extensión del elemento subjetivo de imputación, en la que se involucra, generalmente, su propia culpa o dolo, diversa de la que puede tener el agente primario que provocó el menoscabo. Es así como se hace referencia a las figuras citadas de culpa in eligendo o la culpa in vigilando, que viene a ser propia, no por la causación directa del daño, sino como criterio de imputación determinado por una incorrecta elección de la persona que produjo la lesión, o bien, por una deficiente vigilancia en el quehacer cotidiano de aquel agente productor directo del daño. Como se puede ver, se expande el criterio de imputación (se insiste, normalmente subjetivo, dolo o culpa) para alcanzar el patrimonio de un tercero distinto de quien dañó.

Bajo esta figura, existe un solo centro u objeto indemnizatorio, que viene constituido por un mismo conjunto de lesiones o una misma lesión, en la que se amplían las personas responsables, acudiendo al fenómeno de una falta suya (propia), en tanto este nuevo responsable (tercero que eligió o no vigiló) incumple sus obligaciones respecto del tercero que produjo el daño. Se extiende, como se ha dicho en forma reiterada, el criterio de imputación para poder alcanzar el patrimonio de un sujeto

distinto de aquel que produce la conducta dañosa (sin perjuicio, claro está, de la propia responsabilidad del agente causante directo de la lesión).

Se genera una responsabilidad de persona adicional (tercero), sobre la base de un criterio de imputación propio (un hacer u omitir con negligencia o imprudencia). Es decir, el tercero responde en última instancia, no por la culpa de un ajeno, sino por la culpa propia respecto de la acción u omisión de quien causó la afectación de los intereses subjetivos de la víctima.

Bajo esta hipótesis, hay exoneración de responsabilidad por lo que podríamos llamar exculpación, en la medida en que compruebe que, no operó de parte de este tercero que se pretende responsabilizar, ninguna culpa o dolo vinculada con aquella persona que directamente produjo la afectación a la situación jurídica de las víctimas.

Una vez clarificada la diferencia entre una y otra figura, y regresando a la responsabilidad por daño indirecto o consecuencial, se puede afirmar que para el nacimiento de la obligación reparadora de la víctima secundaria (tercero), basta la antijuricidad de la lesión ocasionada a la víctima inicial. Esto implica afirmar que el agente productor del daño ha de responder por la lesión refleja, no porque hubiere actuado con dolo, culpa, funcionamiento anormal, ilícito, normal, lícito u objetivo frente al tercero, sino porque a propósito de su conducta, y por efecto colateral, produjo también un daño a ese tercero. Se trata simplemente de reconocer a ese tercero, la indemnización de un daño que no debe soportar, sobre la base antecedente (como hemos dicho ya) de una antijurídica y previa lesión a una persona vinculada.

En el singular caso de la responsabilidad objetivo, se prescindirá de ese criterio de imputación de base y, por ende, también se elimina respecto del tercero, pues bastará tanto para la víctima primaria como el tercero dañado, la existencia del daño y del nexo causal para endilgar la responsabilidad patrimonial al agente productor o generador de la conducta dañosa.

EL VÍNCULO INTERSUBJETIVO. EL VÍNCULO NECESARIO ENTRE LAS VÍCTIMAS DE LA LESIÓN.

Es evidente, que para la procedencia de la responsabilidad indirecta ha de existir un vínculo entre el afectado de primer nivel (lesionado base u originario) con el afectado de un segundo nivel (tercero).

La gran interrogante es: ¿Cuál ha de ser ese vínculo?

En primer término, es válido admitir que la relación familiar, consanguínea o por afinidad, es no solo suficiente, sino la más común para endilgar la obligación al sujeto responsable. Esta condición abarca, desde luego, la unión de hecho, la sociedad de hecho, sean las personas de este o distinto género.

Pero en realidad, el vínculo necesario para convertirse en tercera persona afectada puede ser diverso del familiar[4] (sea por consanguinidad o afinidad). Puede, con independencia de lo anterior, constituirse como un mero vínculo afectivo, de manera tal que, esa tercera persona, se convierta, razonablemente, en víctima por efecto de una lesión distinta.

Existen dos posicionamientos claros del tercero que recibe la lesión como una onda expansiva. Una en la que, sin mediar acción suya, recibe como simple sujeto pasivo el efecto dañoso a consecuencia de la lesión a la víctima primaria. Sería el supuesto de una afección por daño moral subjetivo o daño psicológico, sin eliminar un posible daño, o más bien, perjuicio patrimonial. Sobre este, volveremos en el siguiente apartado.

Otra es la situación, en la que por aquel vínculo con el lesionado originario, ese tercero despliega acciones necesarias, lícitas y favorables a la víctima inicial o primaria. Tal es el caso de atenciones personales para con aquélla, abandono de

---

[4] MORENO MARTINEZ. J. Daños Indirectos En Familiares Y Terceros Por Causa De Lesiones. ARANZADI, 2011, España.

su trabajo, adquisición de créditos, proyectos efectivos pero desechados, sin excluir las lesiones extrapatrimoniales.

Este segundo supuesto merece de una mayor atención, puesto que la lesión que sufre el tercero por su legitima acción ha de ser necesaria en función de la víctima primaria. Así, por ejemplo: atención por una grave enfermedad o secuela de una persona miembro del núcleo familiar. De alguna forma, el tercero se ve compelido, moral o legalmente a modificar su situación fáctico-jurídica, lo que precisamente se confirma como causa directa y adicional de su lesión. En muchos de estos casos, emerge una solidaridad especial del tercero para con la víctima originaria. Es bueno advertir también, que el consentimiento o anuencia del tercero para dicha variación de su status no se configura como eximente, a título de culpa de la víctima.

Lo cierto del caso, es que se excluye la responsabilidad patrimonial frente al tercero remunerado por la colaboración para con la víctima originaria.

Con la finalidad de tener un panorama más claro por medio de ejemplificación, es posible mencionar a lo largo del tiempo, varias situaciones donde se ha presentado el tema que nos ocupa:

1. La noche del siete marzo de 1930, el señor Carlos Cabanis Worren, conducía un tren bananero con 45 carros en condiciones de peligrosidad. Al llegar a la estación, la locomotora chocó con unas mulas que se interpusieron en la vía, con lo cual, la locomotora y varios carros volcaron. En el percance, don Carlos perdió la vida. En virtud de ella, la viuda de don Carlos, Mercedes Cervantes Rojas, en nombre personal y de su hijo, demanda empresa Northren Railway Company, reclamando la indemnización por los daños y perjuicios para ella y su hijo. Reclama 120 mensualidades de salario, que se consumían para en ella y su hijo, más una pensión alimenticia de $66 dólares mensuales por la vida probable de su esposo, que a la fecha del deceso contaba con 45 años. Adicionalmente reclama una renta fija para su hijo hasta que cumpla 18 años. Como dato a destacar, interviene como apoderado de la actora, el licenciado Ricardo Jiménez Oreamuno.

El Juez de Primera Instancia rechazó la demanda y acogió la defensa de fuerza mayor. La Sala Civil (órgano de apelación), integrada por los jueces Antonio Picado Guerrero; Pedro Iglesias Flores y Enrique Guier Sáenz, confirmaron la sentencia. La Sala de Casación en el año 1942, por mayoría, atendiendo el recurso de la parte actora, entra a distinguir la figura del caso fortuito y la fuerza mayor, de acuerdo con la doctrina del momento y las propias actas del Código Civil, e interpretando el numeral 1048 de dicho Código aborda a la conclusión de que cabe responsabilidad de la empresa demanda. Debido a ello condena a indemnizar a la viuda actora y a su hijo, a causade la muerte de don Carlos Cabanis Worren, a una renta indemnizatoria de $30 a partir de marzo de 1940 (fecha en la que cesó la indemnización de la Ley de Accidentes de Trabajo) y durante todo el período de vida probable del señor Cabanis. De igual manera concedió una renta indemnizatoria fija para el hijo por la suma de $20 mensuales, a partir de que cumpla los 18 años y hasta que alcance los 21 años. Adicionalmente otorgó la posibilidad a la parte actora de sustituir dichas rentas periódicas por una indemnización global de $3.144, 44 para la viuda y de $653,25 para su hijo. Dos de los magistrados de Casación declaran sin lugar el recurso y confiman las sentencias desestimatorias de la demanda. Ambos consideraron prescrita la obligación e inaplicable el numeral 1048 del Código Civil. [5]

2. La policía mata de un disparo al joven José María Aguilar Quirós, cuando este huye ante la prevención policial de detenerse. El joven no portaba arma alguna. Su madre Dulcelina Quirós Olivares interpone proceso contencioso contra el Estado, reclamando indemnización por la muerte y una renta equivalente a la que el difunto le pudiera haber otorgado. El Tribunal Contencioso Administrativo, mediante sentencia N°551 de las 9 horas 30 minutos del 21 de agosto de 1973, modificó la sentencia de condena que había otorgado el Juez de Primera Instancia (Lic. Álvaro Fernández Silva) en cuanto había otorgado daño moral y una renta para solventar sus necesidades

[5] Sala de Casación Civil. 1942. 7 de mayo.

económicas de alimentación, vestido y alojamiento, por todo el tiempo de vida de la actora. A su vez, el Tribunal de segunda instancia, revocó, como se indicó, dicho extremo indemnizatorio, y en su lugar otorgó una indemnización fija y única de 25.000,oo colones. Esto por cuanto no se demostró que el fallecido trabajara ni diera ayuda o mantuviera a su madre.[6]

3. En junio de 1965, un grupo de niño y niñas salió hacia Honduras para varias presentaciones de danza clásica. Iban acompañadas de algunas padres, madres y tutoras. El Choluteca, Honduras, el autobús tuvo un grave accidente que cobró la vida de las niñas, madres y acompañantes. Debido a ello, varios de los herederos sobrevivientes interpusieron proceso ordinario contra las empresas de Transporte contratadas y contra el INS, reclamando el pago de los daños y perjuicios. El Tribunal Contencioso Administrativo mediante sentencia de las 9 horas 30 minutos del 07 de mayo de 1975 condenó a las empresas del Transporte (autobuseras) al pago de los daños y perjuicios causados a los herederos a consecuencia del fallecimiento de las personas fallecidas. Dicha sentencia fue confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en esta última la discusión giró sobre la prescripción del contrato de transporte, dando por sentada la responsabilidad en los demás aspectos[7].

4. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el año 87 refiere al daño indirecto. Como contexto del caso, se ocasiona una colisión de una radiopatrulla estatal con el vehículo de una joven de 27 años. La joven (Ermida Maria Bravo Sthal) muere días después en el hospital. En el proceso penal se condena al policía conductor de la radiopatrulla por homicidio y al pago de daños y perjuicios interpuesta por su padre. En ejecución de sentencia, tanto el padre como la madre de Ermida, interponen ejecución de sentencia contra el patrullero y subsidiariamente contra el Estado solicitando daño material,

[6] Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 1973. Voto 551. 21 de agosto.
[7] Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 1975. 7 de mayo.

daño moral y perjuicios. Primera y segunda instancia condenan y el Estado interpone recurso de casación, señalando como argumento fundamental que los daños que corresponden son los personalísimos de la fallecida Ermida, no los que sufrieron sus padres que para todos los efectos son terceros. Casación confirma las sentencias de primera y segunda instancia y refiere al daño indirecto de seguido:

> *"…Considerando "VI.- Por regla general sólo es indemnizable el daño que sufre el directamente perjudicado por el evento dañoso; se incluye en ese grupo a todas las personas que de una forma u otra soportan los efecto de aquel evento. Las obligaciones civiles que nacen de delitos y faltas se rigen por las disposiciones del Código Penal; en materia penal no se limita la indemnización a favor del perjudicado directo, pues se concede también a acreedores alimentarios o a herederos legales del ofendido. El daño que se causa a la víctima es diferente que el que se causa a sus parientes allegados; son distintos, en caso de accidente, el dolor psico-físico que la lesión mortal hace sufrir a la víctima, y el daño moral que experimentan sus allegados. Pero ambos son indemnizables en dinero; el daño de los parientes comprende el dolor que se sufre en razón del vínculo paterno filial unido a circunstancias de índole económica, todas las cuales conducen a una indemnización…"*
>
> *Considerando VII.- El Código Penal contiene normas sobre daño moral. El derecho de percibir la indemnización está regulado con el de pedir la indemnización del daño material. Está otorgado el derecho tanto a favor del ofendido directo como a favor de los herederos legales y de los acreedores alimentarios en caso de fallecimiento. Nuestro Código no especifica de manera clara y expresa si la indemnización es por el daño moral sufrido por la víctima o si lo es por el sufrido por sus herederos. En los fallos dictados en este juicio no se hizo distinción sobre este punto. La doctrina considera que existen ambos…"*[8]

5. En el año 1988 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en su voto 114 condena a pagar solidariamente al policía y al Estado 2.051.000,oo colones en concepto de renta por alimentos y 400.000 colones por daño moral,

[8] Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 1987. Voto 49. 22 de mayo.

como motivo del asesinato de un hombre, quien tenía esposa e hijos dependientes.[9]

6. En el expediente 16-6118-1027-CA, el señor Rafael Esquivel Leitón presenta demanda contra el Estado, debido a que se le privo preventivamente de su libertad más de 6 meses, resultando ser inocente por certeza sin embargo, durante el transcurso de este tiempo, su familia se ve afectada indirectamente por este acontecimiento, ya que el negocio de comidas familiar se ve afectado debido a las visitas continuas a la cárcel por parte de la esposa Anabelle, quien a su vez era la única quien atendía además del señor Esquivel, quien hacía las entregas a domicilio, por lo que fue imposible mantener el comercio a flote y provocó el cierre. Así las cosas, su hija menor pierde el año escolar por afectación psicológica al ver a su padre encarcelado. La casa de habitación familiar, se ven obligados a venderla en vista de no poder hacer frente al préstamo bancario, al no percibir ingreso alguno. Es por esto, que es plausible el daño indirecto proporcionado a su núcleo familiar desencadenado por una actuación por parte de la Administración.

Daño moral indirecto subjetivo familiar:

A nivel internacional, principalmente en el ordenamiento argentino, el tópico ha sido desarrollado en mayor medida. Es por esto por lo que la jurisprudencia, principalmente de la Sala de Casación Civil Argentina, incorpora el concepto conocido como "*dolor de amor familiar"*[10]*.* Este consiste en un "dolor de amor en ***derecho***", esto quiere que dicho daño es indemnizable si se encuentra relacionado directamente con el concepto jurídico de ***familia.*** En otras palabras, para poder considerar a un individuo como afectado indirectamente debe mediar una

[9] Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 1988. Voto 114. 22 de abril
[10] Sala de Casación Civil. Emilio Ordoñez Mutis y Lucila Ordoñez Barco contra el Departamento de Santander.

vinculación legal amparada por el derecho que no es más que el vínculo de parentesco.

Es bien sabido que a nivel tanto internacional como nacional, las figuras jurídicas válidas para el ordenamiento jurídico deben estar respaldadas por una fuente del Derecho. En este caso, la ley ampara el concepto jurídico de **FAMILIA**, en sentido estricto como aquel grupo formado por la pareja, sus ascendientes y sus descendientes, así como por otras personas unidas a ellos por un vínculo de sangre, matrimonio, a los que el ordenamiento impone derechos y obligaciones. Consecuentemente, no existe dentro del precepto legal la contemplación de un simple vínculo afectivo por ser un mero vínculo de hecho.

Es por esto, que es posible afirmar entonces, que las relaciones basadas meramente en un vínculo afectivo, como lo son los noviazgos, amistades, no cumplen con el factor jurídico requerido para ser susceptibles de indemnización por daño indirecto.

1. En el año En el año 1990 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ordena indemnizar tanto a la abuela como a los padres de los menores por los daños sufridos por la muerte del abuelo y del niño, quienes caen con el vehículo en movimiento dentro de un hueco en vía nacional que se encontraba completamente cubierto por agua. La Sala establece culpa concurrente del abuelo al conducir por aquella vía y establece una responsabilidad de la Municipalidad de un 65% de las lesiones sufridas de la abuela y la niña.[11]
2. En el año 1991 el Tribunal Contencioso Administrativo, condena a la Caja Costarricense de Seguro Social a pagar 5.000.000,oo de colones por daño moral al esposo (víctima indirecta), por el deceso de la señora (víctima

[11] Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 1990. Voto 263. 22 de agosto.

directa), a quien se le realizó una transfusión de sangre contaminada con Hepatitis B. Se deniegan los daños reclamados por la sucesión.[12]

Daño moral colectivo:

Por su parte a nivel nacional como internacional el daño moral colectivo, que en este caso se podría calificar como indirecto, es posible que se configure de varias aristas sociales.

Por su parte, los autores platenses Morello[13] y Stiglitz muestran su posición en cuanto al daño moral colectivo. Se presentan bajo la idea de que el daño moral social se ve caracterizado por el sufrimiento común de varios individuos, quienes soportan el daño precisamente por formar parte ese determinado conjunto social, vgr. Intereses difusos, intereses colectivos, intereses corporativos, entre otros.

Ambos autores, de manera tácita, reafirman el postulado analizado en el primer capítulo, en cuanto al vínculo jurídico que debe existir para el reclamo indemnizatorio correspondiente por el daño ocasionado. Ahora, si bien es cierto ninguno de los dos autores hace referencia expresa de un daño moral indirecto colectivo, es posible desgranar dicho concepto y adecuarlo a la figura de nuestro interés.

Ahora bien, si se analiza desde el punto de vista ambiental, una vez que se lleva a cabo el impacto ambiental, este de manera indirecta provoca un desequilibrio en el bienestar de la colectividad[14] configurándose el daño aquí mencionado.

Un claro ejemplo de esto es la polución[15], la cual genera una serie de efectos negativos en el bienestar de las personas, provocando de esta manera una

[12] Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 1991. Voto 153. 5 de abril.
[13] Morello A. 1981. La defensa de los intereses difusos. Rev J.A.
[14] Los daños colectivos y la reparación, 1ª ed. Universidad, 1993, Buenos Aires
[15] Depalma j. 2000. Los nuevos daños soluciones modernas de reparación 2. Editorial Hammurabi SRL. Buenos Aires, Argentina. Pág. 171

responsabilidad por el daño derivado de la contaminación ambiental[16]. Ahora bien, ahondando más en el tipo de daño colectivo indirecto, existe una calificación aún más específica como lo es desde la perspectiva moral. Esto implica que el afectado ya no es solamente una persona física o jurídica en su esfera individual, sino que se torna en un gremio con una misma causa en común, que se ve afectada en sus derechos o intereses vitales como lo son la paz, tranquilidad anímica, integridad física, honor, entre otros, es decir desde un punto de vista de la psiquis.

El aspecto más desafiante en cuanto a esta especificidad de la moral es que se busca la reparación de un daño extrapatrimonial que, al ser intangible, hace más compleja su evaluación, así como determinación monetaria pero que una vez comprobado el daño y su nexo de causalidad, resulta imperante resarcir.

Sección III: Demarcación del daño moral indirecto en su vertiente objetiva

- Circunscripción de la vertiente objetiva susceptible a reparación patrimonial de la Administración

Si bien es cierto en esta etapa del proyecto final se posee conocimiento general en cuanto a la responsabilidad de modo extendido, es necesario traer a colación ciertos puntos claves que permitirán delimitar la parte objetiva de una responsabilidad[17] por daño moral indirecto.

Daño indirecto

En la responsabilidad patrimonial extracontractual por el denominado daño indirecto, se produce una expansión del elemento objetivo, es decir de la lesión

[16] Peña M. 2011. Daño Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente. Investigaciones Jurídicas S.A. Costa Rica.
[17] Rivero JM. 2001. Responsabilidad Civil Tomo II. Ediciones Jurídicas Areté. San José Costa Rica. Pág 111

misma (daño), que ya no se limita a la víctima originaria (como receptor primario), sino que, se establece una responsabilidad para con terceras personas distintas de las inicialmente lesionadas; esto, por cuanto reciben la onda de afectación. Es decir, se le conoce como indirecto ya que el perjuicio resulta de la conexión del evento dañosos con un hecho distinto. En alguna doctrina se conoce como daño "mediato"

Como se puede observar, se extiende a terceros en este caso, no la responsabilidad (obligación) frente a la víctima; sino el derecho indemnizatorio mismo (acreencia) de la víctima respecto de aquel que con su conducta le produjo, también, una lesión a los bienes jurídicos extra-patrimoniales, como lo son los derechos de la personalidad (integridad física, honor, intimidad, imagen propia, entre otros).

Ya no solo se cambia el cuadro de análisis del responsable frente a los sujetos pasivos de la conducta lesiva, sino que además se extiende, según se viene diciendo, el elemento objetivo[18] de la responsabilidad, a saber, la lesión (traducido en los daños y perjuicios) que por efecto rebote o por consecuencia, sufren terceras personas adicionalmente y por extensión a la inicialmente afectada.

Desde esta perspectiva, es equivocado afirmar que opera una responsabilidad por daños que **no causó** el agente productor de la lesión. No se trata de atribuir una obligación indemnizatoria por daños[19] que causó otra persona (tercero); pues desde luego, se compromete el patrimonio de quien efectivamente fue causante de la lesión, tanto para la víctima de primer plano o nivel, como para quienes sufren el impacto negativo por expansión. Dicho de otro modo, quien genera el daño y responde por él, lo hace no por un daño ajeno o inconexo, sino por la lesión que efectivamente produjo más allá de la víctima inmediata, y que, por esa razón, se ha dado en llamar indirecto, o bien, nos permitimos calificar como *reflejo*, o por *extensión*, o si se quiere (como lo ha denominado la doctrina extranjera francesa) *dommages par ricochet o bien, dommages consécutifs.*

En definitiva, en el daño por hecho de un tercero, se amplía o añade un sujeto responsable (obligado a indemnizar, sujeto pasivo), en tanto que, en el daño

[18] Zanoni E. 1987. El Daño en la Responsabilidad Civil. Editorial Astrea. Buenos Aires. Argentina. Pág 169.
[19] ROCA, ENCARNA. Derecho de daños. Textos y materiales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.

consecuencial, se incorpora en la cadena de la responsabilidad a una persona adicional, que, de igual forma, sufre daños y perjuicios. Se trata, si se quiere, de una víctima derivada.

Nexo causal

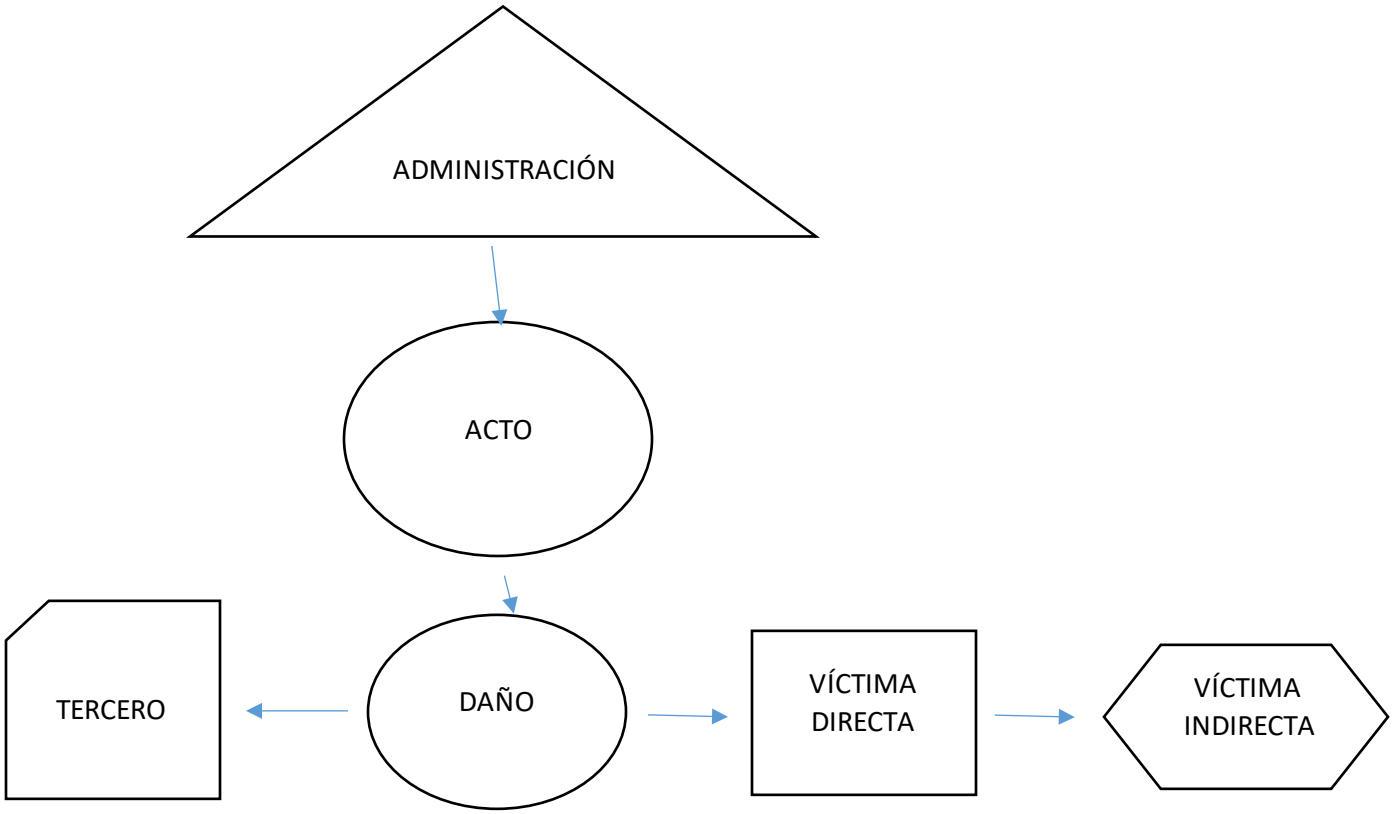
Existen “etapas” en cuanto a la determinación de la relación causal. Comenzando por la relación física, la cual correspondería a la mejor conocida como fáctica, y es aquí donde se presenta una correspondencia entre dos situaciones ciertas. Este nivel de valoración se somete a un criterio más científico o técnico, manteniéndose así a un nivel meramente descriptivo.

Ahora bien, como base se comienza en el nivel factico sin embargo no es del todo posible manejar la situación en este nivel y de ahí sacar conclusiones acertadas. Es por esto por lo que se acude como segunda “etapa” al aspecto valorativo. Es aquí donde la disposición de un jurista debe sopesar la situación contemplando tanto el plano factico, como los intereses y repercusiones metajurídicas en juego.

Inicialmente importa aclarar, no se trata de un fenómeno en el que la conducta o hecho productor recae, directamente, sobre una pluralidad de víctimas en forma inmediata o progresiva (vgr. un accidente de un autobús en que resultaron heridos varios pasajeros, o, una contaminación en el acueducto público de agua potable que intoxicó a varias familias).

En el supuesto bajo análisis, la lesión del tercero (víctima indirecta) no se produce, directamente, por la acción u omisión del que ahora es responsable (pues en tal caso no tendría nada de consecuencial); sino que la lesión del tercero viene dada a consecuencia de la lesión que sufrió la víctima primaria tantas veces mencionada. Es esa, la lesión que inicialmente sufre la persona impactada por la conducta del responsable, la que, a su vez, produce, para este tercero vinculado, una lesión propia, ya sea patrimonial, psicológica, moral, o incluso física.

Por ello es indirecta o refleja, en cuanto la afectación del tercero se da, **no** por incidencia, última o inmediata, de la conducta inicial desencadenante del daño (que podemos denominar primario). La afectación del tercero, según se ha dicho ya, se produce como consecuencia (aquí sí), <u>última y directa</u>, de aquella lesión sufrida por la persona vinculada (inicial y directamente lesionada por la conducta del responsable). De modo que, sin la lesión de esa víctima primaria, no habría lesión del tercero afectado. Por tanto, es aquélla (lesión de la víctima inicial), la que se convierte en causa directa y última de la lesión para con el tercero.



Empero, hay que añadir para evitar confusión, que aquella acción u omisión emanada del agente responsable que lesiona a la víctima primaria (y que según se viene diciendo no es causa última ni directa para la lesión del tercero) sí es **causa eficiente y suficiente** en la lesión de éste. De algún modo, la lesión primaria u originaria se configura como presupuesto causal imprescindible de la que es refleja

para el tercero. Tanto así, que basta decir que, sin la lesión primaria, no existe secundaria ni refleja o indirecta.

Acorde al autor Boffi Boggero[20], el daño inmediato es aquel que acontece según el curso natural de las cosas y mediato al que surge de ese curso, pero con el complemento de la conexión con un acontecimiento distinto. En otras palabras, un evento dañoso va a tener dos consecuencias, en su mayoría, la inicial es aquella primera víctima a quien se asocia con el evento dañoso, mientras que la víctima indirecta, va a ser aquella que se ve afectada por el evento sin embargo de un modo contrario a la víctima inicial. Cabe aclarar, que el sujeto aquejado, no necesariamente resulte en el mismo suceso, sino que puede verse afectada en un lapso temporal distinto al suceso productor de responsabilidad[21].

En resumen, nos enfrentamos a un nexo causal de segundo nivel, pero frente a una causa igualmente determinante y eficiente. Es por esto por lo que cabe preguntarse si la responsabilidad de resarcimiento de una afectado indirecto se delimita en un espacio temporal especifico o resulta indefinido.

Subsistencia.

Otro aspecto puntual que se debe de analizar por parte de los juzgadores a la hora de resolver dichas situaciones es la permanencia del daño, en otras palabras, el menoscabo debe encontrarse aún sin reparación previa. Esto se encuentra relacionado con el nexo causal supra mencionado, ya que, al comprobarse la relación entre la causa y el daño, también es necesario comprobar que el mismo no haya sido resarcido aún. Con lo cual también cabe resaltar que el resarcimiento del daño de la víctima directa no implica automáticamente la compensación del daño indirecto, ya que como es bien sabido son dos figuras o víctimas distintas. Es aquí

[20] Boffi Boggero. L. 1985.Tratado de las Obligaciones. Astrea. Buenos Aires.
[21] Rivero JM. 1999. Responsabilidad Civil Volumen I. Ediciones Jurídicas Areté. San José, Costa Rica. Pág 98.

donde se aplica el principio indemnizatorio, que consiste en que el sujeto dañado se enriquezca sin causa mediante el cobro múltiple de un hecho dañoso. De hecho, si la indemnización ya hubiera operado, estaríamos frente a la figura de una falta de interés actual, o bien, de una cosa juzgada, pero nunca frente a una indemnización ya otorgada.

Así lo dispone el artículo 202 de la Ley General de la Administración Pública, cuando señala que: “El administrado **o tercero** nunca tendrá derecho a más de una indemnización plenaria por el daño recibido…”

Capítulo II. Daño moral indirecto familiar o social en el ordenamiento jurídico

Sección I: Desconocimiento doctrinario de la figura del daño moral indirecto en el ámbito familiar o social.

Para poder analizar el daño que es consecuencia de un hecho delictuoso y al establecer la responsabilidad civil derivada del hecho punible vemos que además del daño material se encuentra el daño moral[22].

En sentido amplio se entiende por daño toda suerte de mal, material o moral.

El daño material afecta directamente sobre las cosas del propio dominio o posesión, o en los propios derechos o facultades. Este es resarcible a través de una indemnización pecuniaria que valorará, globalmente todos los daños patrimoniales causados a raíz de la acción u omisión. Esta estimación será realizada por el juez, pudiendo emplear los servicios de peritos; en la determinación de esa indemnización deberán tomarse en cuenta las calidades personales del ofendido, tales como edad, sexo, profesión, sueldo, las repercusiones del hecho ilícito en la vida del damnificado civil, el valor de las cosas, gastos de curación, de reparación, etc.

Desde una concepción clásica, el daño moral se ha conceptuado como un: “daño no patrimonial consiste en el conjunto de dolores físicos y morales que objetivamente no pueden encontrar un equivalente en dinero, pero que aproximadamente y con un criterio equitativo pueden encontrar un equivalente subjetivo”.

Alfredo Orgaz lo define como "el ataque a las afecciones legítimas: dolor provocado en la víctima o en su familia por delitos contra la vida, la salud o la honestidad; humillación por la revelación de un secreto deshonroso, afligente; sufrimiento por una calumnia o una injuria y en general el ataque a los sentimientos por actos contrarios a la inviolabilidad de la vida privada, o sea lo que los autores llaman la

[22] Torrealba Navas F, Responsabilidad Civil, Editorial Juricentro, Costa Rica, 2011.

propia esfera del secreto o la integridad privada y en el derecho angloamericano, derecho de intimidad”[23].

FAMILIAR

Es interesante constatar además que cierta parte de la doctrina tiende a definir el daño moral, contraponiéndolo al daño material, cuya distinción se manifiesta, de acuerdo entre dos tipos de criterios: según los derechos afectados por un lado y de acuerdo con el resultado del hecho delictuoso por el otro.

Para aquellos que se apoyan en el primer criterio que, si lo afectado es un derecho extrapatrimonial a la víctima indirecta, aunque sus efectos sean patrimoniales, nos encontramos en presencia de un daño moral rebote. Para este sector doctrinario, el daño moral presenta dos facetas:

a) Daño moral puro -es cuando se lesiona- un derecho extrapatrimonial sin vulnerar el patrimonio del lesionado.

b) Daño moral con repercusiones en el patrimonio: aquí el acto lesivo tiene consecuencias materiales.

Para los seguidores del segundo criterio, habrá daño moral cuando se haga sufrir a la persona, aunque no tenga efectos sobre su patrimonio.

Bajo el concepto de daño[24] moral se distinguen dos tipos:

1. Daños morales "strictu sensu" que se limita a la psiquis de la persona, sin tomar en cuenta alguna de las repercusiones patrimoniales o materiales que acarrea, como es el caso del daño moral indirecto sufrido por el cónyuge sobreviviente ante la muerte de su consorte.

---

[23] ORGAZ, ALFREDO: «El Daño Resarcible», Ediciones Depalma,1967, Buenos Aires, páginas 188-189.

[24]ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde en Trigo Represas, Félix A., López Mesa, Marcelo J., Tratado De La Responsabilidad Civil, Tomo III, Ed. La Ley, 1º Ed., Buenos Aires, 2004, p. 59.

2. Daños morales objetivados - es aquel que tiene una repercusión económica, "como el descrédito que disminuye los negocios, los disgustos que debilitan la actividad personal y aminoran la capacidad para obtener riquezas, en suma, los daños morales que causan una perturbación de carácter económico".

SOCIAL

Ya se habrá notado que cuando se hace referencia al daño social[25] (expresión por demás imprecisa en virtud de su contenido indeterminado), en realidad se hace referencia a la lesión de intereses difusos y colectivos.

Artículo 70.- Víctimas

Serán consideradas víctimas:

a) *La persona directamente ofendida por el delito.*

b) *El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en común, el hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.*

c) *Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.*

[25] El Daño Social: Su Conceptualización Y Posibles Aplicaciones. Lic.Ana Lucía Aguirre Garabito y Licda. Irina Sibaja López. Revista Judicial, Costa Rica, Nº 101, 2011.

d) *Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses.*

1.- **ACCIÓN CIVIL FACULTATIVA**

En primer término, de la norma se desprende que se trata de una acción **facultativa**, sea, que el Estado (a través de la Procuraduría) podrá ejercer la acción civil cuando estime que se han producido lesiones a los intereses colectivos o difusos. No se trata de un mandato imperativo para determinados supuestos, sino que se otorga un amplio margen de valoración (discrecionalidad en sentido amplio) para determinar la posible lesión.

2.- **LEGITIMACIÓN ACTIVA**.

Como se puede observar, en principio se confiere una legitimación restringida al Estado como representante de los intereses públicos, en la línea de contenido dispuesta por el numeral 113 de la Ley General de la Administración Pública. Empero, por medio del artículo 70 del mismo Código Penal, se expande la legitimación a organizaciones formalmente constituidas, que, como parte de su objeto, representen, en algún grado, intereses colectivos o difusos, tal como es el caso de asociaciones, fundaciones, cámaras, sindicatos, cooperativas, federaciones, etc.

Se expande la legitimación más allá de la representación estatal. Cabe cuestionarse si dentro de esta última puede incorporarse a la Contraloría General de la República. En nuestro criterio, de una interpretación literal, queda excluida para tal reclamo. No obstante, atendiendo a sus funciones, a su relevancia y la legitimación que le otorga nuestro ordenamiento jurídico (artículo 10 inciso 1, acápite a) e inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo), puede sostenerse válidamente su legitimación para intervenir en esta acción específica.

3.- **CAUSA. REQUISITO BASE. HECHOS PUNIBLES**

El numeral 38 del Código Penal, restringe la causa inmediata de esta lesión a la existencia del hecho punible, lo cual lleva en forma directa a un nuevo cuestionamiento: ¿cabe reclamar lesión a los intereses difusos o colectivos cuando se excluya la existencia de hecho punible o se hubiere eximido, o bien excluido, de responsabilidad penal a quienes figuren como imputados? En nuestro criterio, y para esta materia, no parece posible. Lo anterior, no por desconocimiento del artículo 40 del Código Procesal Penal[26], sino, porque la limitación deriva del mismo artículo 38 en cuanto sujeta su procedencia al hecho punible, que se alza entonces como presupuesto *sine qua non* de la figura resarcitoria de comentario.

Lo anterior permite reflexionar sobre la procedencia de la lesión a este tipo de intereses fuera de la acción sancionatoria de carácter penal. La respuesta a esta nueva interrogante ha de ser abordada en el apartado general del daño indirecto o reflejo en nuestro ordenamiento jurídico.

Dejando de lado por ahora, la dificultosa definición de los intereses difusos y colectivos de la que se ha ocupado la doctrina y nuestra jurisprudencia no siempre con demasiado éxito, se hace imprescindible señalar que dentro de ellos se han incorporado afectaciones no solo a grupos más o menos indeterminados de personas identificables, si acaso, por un elemento conductor común; sino que se ha incluido con mayor frecuencia la lesión a los intereses nacionales, como visión país o Estado, en un sentido amplio del colectivo nacional, de totalidad poblacional antes que agrupaciones amorfas representativas de intereses supraindividuales.

Problema adicional se presenta con la determinación y prueba de dichos daños, cargada, casi siempre, de una dificultosa demostración. En la práctica se ha acudido a la experticia de diversos profesionales (matemáticos, actuarios matemáticos, contadores públicos autorizados, ambientalistas, etc.) que con insumos bastante

[26] En cuanto dispone que: "La sentencia absolutoria no impedirá al tribunal pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda".

cuestionables (v. gr. Encuestas o entrevistas a pequeños grupos de habitantes -muestras-) han servido de fundamento para el ejercicio de esta acción[27].

Ello sin dejar de lado, la compleja demostración del nexo causal en este campo, según se expuesto ya en los apartados generales de este trabajo.

Con la finalidad de no dejar el tema meramente en una cuestión explicativa, se presentan dos casos recientes a nivel jurisprudencial tanto en el año 2019 como en el año 2023 relacionados con el tópico.

1. Resolución 342-2019: "…II. (...). Es decir, la decisión de confirmar el fallo de juicio y rechazar el daño social pretendido por la Procuraduría no radica en la ausencia de un documento en particular, sino de cualquier clase de prueba que fuese idónea para demostrar ese nexo de causalidad entre la conducta delictiva y un daño efectivo a la colectividad, razonamiento del cual no se evidencia vicio alguno, en tanto, resulta claro que en materia civil, quien reclama un daño de la naturaleza que sea- está obligado a demostrarlo, en todas sus dimensiones y acreditar que el hecho ilícito es el generador de ese daño. Es por ello que esta Sala estima que la pretensión del procurador no se sustenta en un yerro del fallo, sino en una inconformidad basada en una apreciación sesgada del contenido de la resolución, y que apareja como consecuencia necesaria, que el agravio que pretende acreditar resulte absolutamente inexistente.(...)."[28]

2. Resolución 157-2023: "Es así que, en razón de que los hechos que se tomaron en cuenta en la sentencia 167-2011 del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José, fueron los acusados por el Ministerio Público, lo que tuvo como consecuencia que, por la forma en que se describió la conducta atribuida a Rodrigo Méndez Soto, **los hechos que se tuvieron por demostrados en dicha sentencia en relación a Méndez Soto (hechos**

[27] Como prueba de lo dicho, y tan solo a manera de ejemplo, puede verse el asunto penal con acción civil resarcitoria por daño social, tramitado bajo el expediente número
[28] Sala Tercera e la Corte Suprema de Justicia. 2019. Voto 342. 3 de abril.

demostrados que adquirieron firmeza y por ende, constituyen cosa juzgada), fueron recalificados a los delitos de receptación y favorecimiento real, los cuales no califican como delitos funcionales y por lo cual, no pueden derivar una responsabilidad social (como lo pretende la Procuraduría General de la República), así como tampoco un daño para el ICE (ya que de la relación de hechos del Ministerio Público, no se logra derivar ninguna conducta en detrimento del ICE), situación que resulta totalmente ajena, tanto a la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Electricidad (toda vez que las relaciones de hechos de sus acciones civiles resarcitorias, sí atribuyen conductas que de ser ciertas e imputables, constituirían delitos contra los deberes de la función pública, con un evidente daño, tanto social como para la imagen institucional del ICE). Es en razón de lo anterior que, los hechos en que se basan las acciones civiles resarcitorias interpuestas por la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Electricidad no lograron ser demostrados; y por el hecho de que, conforme al análisis anteriormente realizado, la prueba testimonial que se recibió durante el debate que precedió la presente sentencia, no brindó información que permitiera determinar alguna otra circunstancia de la que se pueda desprender la existencia de un daño social causado por Rodrigo Méndez Soto, se declaran sin lugar las acciones civiles resarcitorias incoadas por la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Electricidad, en contra de Rodrigo Méndez Soto."[29]

[29] Tribunal Penal II Circuito Judicial de San José. 2023. Voto 157.

Sección II: Inseguridad jurídica en la interpretación normativa al daño moral indirecto familiar o social en un proceso ordinario contencioso civil de hacienda

Dicho concepto de daño indemnizable debe analizarse bajo dos componentes, como lo son el factico y el normativo, como se verá de seguido.

1. Bloque Fáctico: se presenta una situación de hecho en donde la realidad del damnificado se ve afectada o amenazada ya sea a nivel material o a nivel intelectual.
2. Bloque Normativo: la ley y la jurisprudencia de la mano con la doctrina gradualmente han logrado establecer qué situaciones fácticas encajan en una categoría tipificada. Es así como la jurisprudencia principalmente y alguna intervención del legislador, que se ha comenzado a delimitar dichas tipificaciones susceptibles de indemnización y así expandir en el ordenamiento jurídico la figura del daño indirecto al punto de poder alcanzar la realidad social cambiante que amerita el reconocimiento de este.

Veamos la procedencia o no del daño indirecto, o bien reflejo o por rebote en los diversos ámbitos sectoriales de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Habremos de empezar, como corresponde, por el ámbito constitucional.

A. CONSTITUCIÓN PÓLÍTICA.

Si bien es cierto, la responsabilidad patrimonial extracontractual se obtiene de múltiples normas constitucionales[30] hemos de centrar nuestra atención en tres de ellos.

a. Es bien sabido que el artículo 41 se configura como el eje central de la responsabilidad a nivel constitucional. En lo que interesa, establece

[30] Artículos 9, 11,33,41,49,50, 140,154 y 194.

en primer término una universalidad subjetiva en la reparación, en la medida que cubre como sujeto titular de aquélla (víctima de la lesión) a TODA persona, ya sea física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, mayor o menor, individual o colectiva.

Entretanto, en su factor objetivo (lesión), refiere con terminología amplia, a cualquier injuria o daño. Esto implica afirmar que lo puede ser directo o indirecto, originario o reflejo o por "rebote". En otras palabras, constitucionalmente no es dable excluir la reparación de las lesiones bajo estudio en el presente trabajo; de modo que, la interpretación de cualquier norma infra constitucional deberá incorporarlos, so pena de abierta inconstitucionalidad.

Por último, cabe añadir que la lesión indemnizable puede ser de cualquier naturaleza, ya sea que se hubiere recibido en su persona, en su propiedad, o bien, en su ámbito moral, incluyendo (claro está) los denominados "familiares" y los "sociales".

Por su importancia conviene transcribir la norma de comentario:

"*Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las* ***injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales****. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes."(el destacado no es del original)*

b. Lo anterior viene reforzado por el párrafo tercero del artículo 49 constitucional en cuanto obliga a la jurisdicción contencioso administrativa y civil de hacienda[31] a proteger, es decir, también a indemnizar, **al menos**, los **DERECHOS SUBJETIVOS Y LOS INTERESES LEGÍTIMOS**: cualesquiera sean; lo que equivale a decir que cubre la lesión de cualquier **INTERÉS SUBJETIVO[32],** para

[31] Y por el principio constitucional de Unidad de Jurisdicción, a cualquier otra.

[32] Para utilizar la expresión de Santamaría Pastor y acuñada por nuestra jurisprudencia nacional, omnicomprensiva tanto de los derechos subjetivos como de los intereses legítimos.

nuestros efectos: directos o indirectos, individuales o supraindividuales.

Indica en su literalidad en mencionado párrafo:

"La ley protegerá, al menos, los ***derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados****." (el destacado no es del original)*

c. La columna vertebral básica de orden constitucional se termina de integrar con la incorporación del canon 50, el que después de asignar para toda persona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, legitima de manera abierta, a toda persona[33], para reclamar la equiparación del daño causado.

   Además de que se dispone la "*equiparación*", concepto más amplio y completo que "indemnización"[34]; se hace referencia "*daño*", sin restricciones ni límites, por lo que habrá de entenderse incorporado (por mayoría de razón) el daño indirecto o reflejo[35].

   A más de lo anterior, se remite a la ley lo concerniente a las responsabilidades correspondientes.

B. NORMATIVA INTERNACIONAL

La normativa argentina[36] es muy clara en cuanto al reconocimiento del daño moral indirecto tanto así que, en su Código Civil, en el título de los actos ilícitos, artículo 1079: *"La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo*

---

[33] En nuestro criterio, se trata más que un interés difuso, de una verdadera legitimación popular.

[34] En cuanto implica reparar, a ser posible *in integrum*

[35] Dispone el artículo 50 Constitucional lo siguiente:

> *"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y* ***para reclamar la equiparación del daño causado.***
>
> *El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley* ***determinará las responsabilidades*** *y las sanciones correspondientes." (el destacado no es del original)*

[36] Zanoni E. 1987. El Daño en la Responsabilidad Civil. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina. Pág 443.

*respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta".*se da de manera expresa al final del este. Esto conforme al principio general en materia de legitimación activa, en donde se pretende la indemnización del daño sufrido, la norma es clara en cuanto a los damnificados directos como indirectos declarándolos legitimados para el reclamo por separados de los daños respectivos.

Por su parte, en la normativa colombiana, si bien es cierto no existe un reconocimiento expreso, si se encuentra contemplado a través del articulado constitucional 16,23,30 y 51. En estos se tratan las garantías sociales que permiten una protección a la figura familiar dando paso así a una interpretación casuística según el caso Emilio Ordoñez, mencionado más adelante, en el cual da pie a una comprobación de daño moral indirecto familiar. Por su parte, el Código Civil colombiano se encuentran disposiciones de orden público, sobre derechos de carácter familiar, como las que regulan las obligaciones entre padres e hijos (art. 288 Código Civil Colombiano), las relativas al patrimonio de familia no embargable (Ley 70 de 1931, artículos 21 y 22), así como la figura jurídica de familia para efectos de reclamos a daños hacia el núcleo (Artículo 2341 Código Civil Colombiano).

Por su parte a nivel europeo, sobresale Francia[37] y España, que si bien es cierto ambos países regulan dicha figura del daño moral indirecto a lo largo de su normativa nacional de forma dispersa, lo cierto del caso es que ambos se basan en la resolución de estas situaciones acorde al Convenio Europeo de Derechos Humanos, específicamente en la interpretación del canon 41: "*Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa"*, el cual establece un reconocimiento del daño equitativo al finalizar el canon. Es por esto que, para que los tribunales concedan una «satisfacción equitativa» se tienen que cumplir cinco condiciones: en primer lugar, que se produzca una violación por parte de un Estado parte de sus

[37] VINEY, G., Traité de Droit Civil. Les obligations. La responsabilité, 1982, París.

obligaciones respecto al Convenio; en segundo lugar, la existencia de un daño material o moral; en tercer lugar, que se pueda probar una conexión causal entre la violación del Convenio y dicho daño; en cuarto lugar, que el demandante solicite la indemnización; y, por último, la ausencia de posibilidad de una completa reparación (*restitutio in integrum*[38]).

C. CÓDIGO CIVIL.

a. Señala el artículo 1045 del Código Civil lo siguiente:

> *"Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia**, causa a otro un daño**, está obligado a repararlo junto con los perjuicios." (el destacado no es del original)*

Se trata de la norma mater (por su generalidad básica y su antigüedad) de nuestro ordenamiento jurídico positivo. ¿Puede entenderse incorporado el daño indirecto y/o colectivo en dicha norma, o, por el contrario, quedan ambos excluidos?

El enfoque interpretativo debe ser dirigido sobre la expresión "*a otro*". Ese otro en modo alguno se limita a la víctima directa o inmediata. Ese otro puede ser, y de hecho, es, cualquier persona que sufra lesión por conducta activa u omisiva del causante del daño. No hay razón para interpretar de manera restrictiva la referencia a la víctima. "Otro" es un tercero dañado, sea indirecto o directo.

Aspecto diverso, es si se trata de un "otro", individual, o, pueden ser varios "otros" (pluripersonal). Es decir, si esa víctima calificada por la norma como "otro" ha de ser individual o puede ser colectivo. En nuestro criterio la norma dispone responsabilidad frente a cualquiera que hubiere sufrido

[38] Véanse van Boven, Th., «Reparations. A Requirement of Justice», op. cit., p. 661; y, van Dijk, P.; van Hoof, F.; van Rijn, A., y Zwaak, L. (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4.ª ed., Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2006, pp. 245-251.

lesión, por lo que cubre la lesión al colectivo, en tanto el reclamante sea parte de éste.

La situación parece diversa cuando nos enfrentamos con el contenido del artículo 704 del mismo Código Civil.

Dispone en su literalidad dicha norma:

> *"En la indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenderán los que, como* ***consecuencia inmediata y directa*** *de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse."(el destacado no es del original)*

Aquí se hace referencia a unos daños y perjuicios ocasionados en forma INMEDIATA Y DIRECTA por el incumplimiento de la obligación. Los vocablos consignados parecen excluir la responsabilidad por daño indirecto, y también al que sea mediato.

Es verdad que podría realizarse un esfuerzo interpretativo para afirmar que allí también se autorizan, o al menos, no se prohíbe, el reconocimiento de aquel daño sufrido por tercero a consecuencia de la víctima inmediata o primaria. Sin embargo, hemos de reconocer que resulta una interpretación forzada, por lo que, lo más conveniente para dispersar toda duda, es provocar su reforma legislativa, tal y como recomendamos en el apartado correspondiente.

D. LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

En lo tocante al ámbito del derecho administrativo, la Ley General de la Administración Pública (como norma legal de base en la materia), presenta un número importante de normas que, al igual que las anteriores, no refieren

expresamente al daño indirecto, pero tampoco lo impiden. Antes bien, aluden a la responsabilidad de la Administración Pública por la totalidad de los daños que ocasione. La expresión "*daños*" ha de interpretarse en sentido amplio, inclusivo de los perjuicios, tal y como lo revela íntegramente el capítulo pertinente como un todo[39].

Al igual que en supuestos anteriores, se estima que deben incluirse la totalidad de los daños, tanto directos como indirectos. No existe razón alguna ni interpretación válida posible para excluirlos.

Así lo confirma el contenido del precepto 191 de la misma ley[40], cuando impone a la Administración Pública su obligación de reparar "***todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos".*** Cabe destacar en este caso, los términos reparar que felizmente utiliza la norma, y la expresión "**derechos subjetivos ajenos"**, que por integración del ordenamiento jurídico pleno, debe extenderse a los intereses legítimos, según veremos en el siguiente apartado.

---

[39] Dispone el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública lo siguiente:

> *"1. La Administración responderá por **todos los daños** que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.*
>
> *2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente." ."(el destacado no es del original)*

[40] Dispone el artículo 191 de la Ley General de la Administración Pública lo siguiente:

"*La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión." (el destacado no es del original)*

De igual manera destacan en la misma ley, los preceptos 196 y 197[41]. El primero en cuanto cubre tanto los daños[42] individuales como los de grupo (supra individuales). El segundo, en la medida en que incorpora (no en exclusiva), tanto los daños morales como los físicos.

Para la responsabilidad del Estado (no ya de la Administración Pública), se presenta norma singular para el tema de nuestro interés, al referir a la responsabilidad de aquél por actividad legislativa[43]. La singularidad se presenta cuando se atribuye responsabilidad por los "*daños causados **directamente** por una ley*". De nuevo aquí se presenta la posibilidad de una forzada interpretación tendiente a cubrir los daños indirectos (salvo justificación razonable para la indicada restricción, que no alcanzamos a descifrar ni mucho menos compartiríamos)[44]. Todo lo cual nos permite sugerir la respectiva modificación de la norma[45].

---

[41] Dispone el artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública lo siguiente:

> *"En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en **relación con una persona o grupo."** (el destacado no es del original)*

Entretanto el artículo 197 de la Ley General de la Administración Pública señala lo siguiente:

> *"Cabrá responsabilidad por el daño de **bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico** causados por la muerte o por la lesión inferida, respectivamente." (el destacado no es del original)*

[42] PIETRO MOLINERO, R. J., El sistema de compensación de daños personales de Nueva Zelanda, (Mimeo).

[43] Bien es verdad que solo refiere a los daños causados por ley, no así a la totalidad de la actividad legislativa. No obstante, por aplicación holística del ordenamiento jurídico, y en especial del Derecho de la Constitución, bien puede afirmarse que en nuestro medio cabe responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad legislativa como un todo.

[44] Se hace referencia tan solo a los daños por virtud de la exclusión de los perjuicios que realiza el mismo artículo para la responsabilidad por conducta lícita y que a todas luces, parece extensiva a la actividad legislativa. Sobre la exclusión que se menciona y nuestro criterio adverso, no hacemos aquí alusión alguna por tratarse de tema independiente que escapa al núcleo central de la presente investigación.

[45] Dispone el párrafo tercero del artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública lo siguiente:

> *"El Estado será responsable por los daños **causados directamente** por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo." (el destacado no es del original)*

E. CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Para los efectos del daño indirecto o reflejo (y aún fuera de este tema), el Código Procesal Contencioso Administrativo, introdujo una modificación de particular relevancia. Incorporó en el ordenamiento jurídico positivo costarricense, la indemnización por lesión a los intereses legítimos[46].

Dispone el inciso 4) del artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo lo siguiente:

*"**Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses legítimos o derechos subjetivos**, podrá pedir la declaratoria, el reconocimiento o el restablecimiento de una situación jurídica, **con reparación patrimonial o sin ella**." (el destacado no es del original)*

Esto nos permite afirmar, con suficiente y sólida base jurídico-positiva, que la lesión a los intereses legítimos, en forma directa o indirecta, individual o supraindividual (colectiva o "social"), en tanto lesionados, merecen y permiten plena indemnización. Lo cual concuerda, en todo, con la legitimación activa amplia y flexible que consagra el mismo artículo 10 del mismo Código en su inciso primero.

F. LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

[46] En realidad, la indemnización al interés legítimo ya se podía obtener del ordenamiento jurídico que regía antes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Así se obtenía del párrafo tercero del artículo 49 constitucional ya citado y transcrito; y de la Ley General de la Administración Pública, por la derogación del canon 193 y por interpretación del 195 a contrario sensu. Más aún, se obtenía de la misma Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por sana interpretación de los artículo 10.1).a) y 91.

Cuando se hace referencia a la responsabilidad patrimonial objetiva, es inevitable acudir a la materia del consumidor y sus derechos.

Pues bien, ocurre que, en este espectro, de igual manera que los anteriores, se realiza una cobertura amplia de la esfera jurídica del consumidor, pues se impone la responsabilidad del productor, proveedor o comerciante, cuando PERJUDIQUEN al consumidor, con independencia de si hubo o no culpa (de allí lo objetivo de la responsabilidad)[47].

Perjudicar implica lesionar, dañar[48]. De modo que es permisible concluir que, cuando a un consumidor se le perjudique, es decir, sea lesionado o dañado, merece reparación patrimonial. Esto aplica bajo los parámetros de la responsabilidad objetiva, sea que se trate de un daño o lesión indirecta o directa, colectiva, "social" o individual.

G. REGLAS VIGENTES SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CÓDIGO PENAL DE 1941.

La responsabilidad patrimonial, por principio, deriva no solo de ilícito civil, de conducta anormal e ilícita (lícita y normal cuando de la Administración se trata), o

---

[47] Dispone el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor lo siguiente:

> *"El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, **si el consumidor resulta perjudicado** por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.*
> *Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.*
> *Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor." (el destacado no es del original)*

[48] De allí que el Diccionario de la Real Academia lo defina como:

> *"Ocasionar daño o menoscabo material o moral."*

Y que, por otro lado, se utilicen como sinónimos del vocablo, los términos:

> *"menoscabar, dañar, damnificar, lastimar, deteriorar, vulnerar, descalabrar, fastidiar, embromar, chivar".*

bien, de ilícito penal. Lo relevante es que se trata de una lesión cuya reparación patrimonial es debida, bien sea por la conducta antijuridica del agente productor, bien lo sea por el deber de no soportar el daño por parte de la víctima.

De esta manera, es absolutamente procedente la responsabilidad patrimonial por daño indirecto o reflejo, o por "rebote", derivada de ilícito penal. A este fin, entran a operar las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, a saber, el Capítulo II, Título IV. Libro I, de dicho Código[49].

En efecto, son varios los artículos del capítulo en cuestión, que se manifiestan sin ambages y en forma clara, sobre la responsabilidad por la lesión sufrida por terceros distintos del ofendido o víctima penal.

El artículo 126 de dichas reglas arranca diciendo:

> *"La indemnización de perjuicios comprenderá, no sólo los que se hubieren causado al ofendido,* ***sino también los irrogados, por razón del hecho punible a un tercero****.*
>
> *El importe de esta indemnización se regulará por los tribunales en los mismos términos establecidos para la reparación del daño en el artículo 24."(el destacado no es del original)*

La norma transcrita es tan reveladora como contundente. Se hace especial énfasis en los perjuicios, como la lesión más frecuente para esos terceros, según se indicó páginas atrás. Y en este sentido, conviene señalar (sin desviarnos demasiado del objeto principal del presente trabajo final), que los perjuicios, por mayoría de razón, no se circunscriben al lucro cesante. En mucho los desbordan, pues incluye además de aquéllos, la privación de cualquier beneficio que pudiera obtener la persona afectada con el hecho productor de la lesión, sea directa o indirecta. Esto los hace ciertos, aunque no siempre actuales, pues en muchas ocasiones serán potenciales.

[49] Esto así por disposición expresa del artículo 13 de la Ley número 4891 de 08 de noviembre de 1971.

Pero lo más relevante del artículo trascrito, es que está voluntariamente dirigido, en forma expresa, a los terceros, es decir a las personas diferentes de la víctima del hecho punible, que sufren consecuencias adversas como consecuencia de éste y en vínculo con el afectado directo.

Es esta norma, ante la inexistencia expresa de alguna otra de semejante contenido, la que habrá de aplicarse en cualquier materia jurídica por integración adecuada del ordenamiento jurídico.

Pero es que debe agregarse que, con la propia literalidad del precepto, se deberán conceder u otorgar a esa tercera víctima, todos y cualesquiera perjuicios ocasionados, sea en forma individual o colectiva si así corresponde. Obsérvese que no se limita al otorgamiento de una pensión alimentaria[50], y para algunos casos, no se dispone una pensión alimentaria alguna, sino una indemnización única en suma equitativa[51], o bien por conmutación en una o varias cantidades totales, a criterio

---

[50] Sobre el posible otorgamiento de pensión alimentaria a terceros como consecuencia de hecho punible, dispone el artículo 128 de las normas vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, lo siguiente:

> *"Cuando a consecuencia del hecho punible se produzca la muerte del ofendido, el condenado satisfará, por vía de reparación, a más de los gastos hechos en obtener la curación o alivio de la víctima, una renta* ***para los acreedores alimentarios legales que recibían del occiso alimentos o asistencia familiar*** *en la fecha de la comisión del hecho punible.*
> *La pensión será proporcionada a la suma que, en la fecha indicada, obtenía o habría podido obtener la persona fallecida con su trabajo o en que deba apreciarse su asistencia familiar, tomando en cuenta la condición y capacidades del interfecto. Los alimentarios gozarán de la renta a partir de la fecha referida, por todo el tiempo en que, normalmente y según la ley civil, habrían podido exigir alimentos del occiso durante el resto de vida probable de éste.*
> *Sin embargo, cuando por cualquier motivo resultare exiguo el monto total de lo adeudado según la regla del párrafo anterior, los jueces podrán obligar al responsable a pagar una indemnización equitativa adicional, que se fijará, cancelará y distribuirá de acuerde con las disposiciones del artículo siguiente." (el destacado no es del original)*

[51] Así lo indica el numeral 129 cuando proclama:

> *"Si a la fecha de la comisión del hecho y por cualquier motivo, los acreedores alimentarios legales del occiso no recibían o no podían recibir de la persona fallecida alimentos o asistencia familiar, el condenado pagará, a título de indemnización,* ***al consorte, descendientes, ascendientes, hermanos, tíos o sobrinos del difunto, que hayan sido declarados herederos legítimos de éste****, una suma equitativa que será discrecionalmente tasada por los jueces tomando en cuenta la naturaleza del agravio sufrido y las condiciones personales del occiso; esa suma, que será cancelada de una vez, se distribuirá entre ellos con sujeción a las reglas civiles sobre el reparto de herencia legítima.*

del Juez y en atención a los intereses de los reclamantes (artículo 130 párrafo segundo)

La normativa de comentario (numeral 130 recién citado) se encarga incluso de especificar, con toda precisión, algunos de los posibles escenarios a presentarse con terceras personas reclamantes que sufren daños indirectos por vinculación cercana y/o dependencia del ofendido fallecido, como es el supuesto del cónyuge supérstite, o bien, cónyuge sobreviviente e hijos menores; o en su caso, tan sólo hijos menores; e incluso se regula la circunstancia de personas inhábiles, o, padres del difunto[52].

Los colaterales *referidos sólo recibirán la indemnización cuando fueren incapacitados y vivieren a costa del occiso." (el destacado no es del original)*

[52] Dispone el artículo 130 de las normas vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, lo siguiente*:*

"El pago de las pensiones alimenticias periódicas a que se refieren los artículos 127 y 128, se garantizará debidamente y el juez fijará el modo y forma de satisfacerlas.

Si así conviniere a los intereses de los reclamantes, el juez podrá conmutar las pensiones futuras en una o varias cantidades totales que correspondan, hasta donde la previsión alcance, al resultado que produciría a la larga el sistema de la renta. En caso de muerte del ofendido se observarán las reglas siguientes:

1°-Si el reclamante fuere ***el cónyuge supérstite****, sin hijos menores, la conmutación se hará a base del resto probable de vida del cónyuge de mayor edad en la fecha de la infracción.*

2°-Si los reclamantes fueren ***el cónyuge sobreviviente y los hijos menores del interfecto,*** *se seguirá el criterio de la regla anterior, o bien se tomará como base lo que falte al menor de los hijos para llegar a la mayoridad, según resulte más equitativo.*

3°-Si se tratare ***sólo de hijos menores****, la conmutación se operará a base de lo que falte al menor de los hijos para cumplir la mayoridad en relación con la vida probable del difunto.*

4°-Si entre los alimentarios figurare ***un inhábil****, la conmutación se hará por el resto de vida probable de éste o por el resto de vida probable del occiso, a base de la edad del mayor de ellos.*

5°-Si entre las personas que recibían alimentos figurare los ***padres del difunto****, la vida del menor de éstos servirá para el cálculo de la conmutación.*

6°-En cualesquiera otros casos de alimentarios, no previstos en las reglas anteriores, se aplicará, si fuere posible, la que guarde mayor analogía dentro de un criterio de equidad, y, a falta de esa analogía, los jueces harán prudencialmente la conmutación." (el destacado no es del original)

Lo expuesto no debe llevar a confusión, pues no se trata de sumas indemnizatorias que correspondían por lesión directa y personal al ofendido. De ningún modo. Se establecen reparaciones patrimoniales a quienes sufren perjuicios propios, derivados del hecho punible cometido contra el ofendido directo y fallecido. Tanto es así que el cuerpo normativo de comentario regula en forma independiente y clara, el supuesto (distinto) de la transmisión de las reparaciones civiles que corresponden a los herederos del ofendido. De esta manera el artículo 134 señala:

> *"La obligación de la reparación civil se transmite a los herederos del ofensor, y el derecho de exigirla, **a los herederos del ofendido**." (el destacado no es del original)*

Es digno de mencionar, el hecho de que, el legislador del 41 previó incluso alguna causal de exoneración **parcial** de la responsabilidad patrimonial del ofensor, cuando establece que:

> *"En los casos previstos en los artículos 127, 128 y 129, **cuando la víctima haya contribuido por su propia falta a la producción del daño**, los jueces podrán reducir equitativamente el monto de la reparación." (el destacado no es del original)*

En este sentido, es evidente que no solo la culpa de la víctima es causal de exoneración, sino también la fuerza mayor o el hecho de un tercero, que al igual que la expresamente mencionada, pueden configurarse como causales de exoneración total o parcial, pese a que la norma transcrita la utiliza como mecanismo de reducción del monto indemnizatorio.

Como aspecto independiente del reconocimiento del daño indirecto en los términos dichos, cabe agregar como elemento de gran relevancia, que las sumas o beneficios otorgados a esos terceros de acuerdo con las disposiciones de los artículos 127 y 128, será inembargables, incompensables, irrenunciables e intrasmisibles (artículo 131)

Sección III*: *Incerteza jurisprudencial para la concreción del daño moral indirecto familiar o social.

Ahora bien, desde el punto de vista del conjunto jurisprudencial, que nos compete en esta sección, a nivel costarricense, a pesar de tener un sistema de cláusulas usuales que permite en general la indemnización de todo tipo de daños, el daño moral no siempre fue bien admitido dentro de estas disposiciones para la reparación de este.

En un inicio, a la hora de solicitar el reclamo, existían tres desafíos para la concreción de daño. Primero la dificultad de cuantificarlo, segundo la dificultad de probarlo, y tercero evitar el lucro a través del sufrimiento humano.

Si bien es cierto, hoy en día no existe una fórmula matemática exacta que abarque dichos tres aspectos y los resuelva, lo cierto del caso es que, si es posible el reconocimiento del daño a través de varios aspectos de análisis, que en conjunto se aproximan a una solución del caso, tal y como se analizaron en el capítulo I del presente proyecto.

Familiar

Sin embargo, de manera concatenada a estos aspectos analizados supra, la jurisprudencia, específicamente la civil, aduce que el daño moral se califica como "in re ipsa", es decir que se desprende de manera innata de los hechos. No obstante, dicho criterio podría ser reforzado para una mejor resolución, tomando en consideración el voto 474-F de la Sala III del año 91.

"…Que la indemnización por daño moral la puede acordar prudencialmente el juzgador si no hubiese base suficiente para fijarla por medio de peritos, de tal suerte que por ser un pronunciamiento facultativo, no se incurre en ninguna infracción, siempre que se esté en ese campo dentro de lo razonable, según las circunstancias de infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido..."[53]

Esto como es bien sabido ya, nos refuerza el concepto de daño moral, sin embargo, el voto continúa más allá y reconoce un derecho indemnizable al existir el lazo jurídico necesario para dicho reclamo como de seguido se anota.

"… En el presente caso se comprende sin mayor esfuerzo que la súbita -aunque tortuosa- muerte de la ofendida implicó un grave sufrimiento de naturaleza psíquica tanto para el marido como para las hijas de la occisa por la angustia y sufrimientos que conlleva la irreparable pérdida de su esposa y madre, por lo que es razonable que se les indemnice como un daño moral, aun cuando esa aflicción no sea reparable por la sola indemnización debida a la víctima [...]. "[54]

Como último aspecto del voto anterior, en ultimas líneas cabría interpretación en cuanto a que no solamente la familia merece una indemnización propiamente por el sufrido por la víctima fallecida sino a su vez son merecedores de una indemnización aparte por concepto de lo sufrido como familia de dicha víctima.

Consecuentemente

Esto nos refuerza el aspecto subjetivo inicialmente analizado, en el cual es posible plantear dicho reclamo ante tribunales bajo la existencia de un lazo jurídico como lo es la familia para el correspondiente reclamo moral indirecto basado en la jurisprudencia nacional a falta de normativa expresa sobre el tema.

[53] Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 1991. Voto 474-F. 13 de setiembre.
[54] Ibídem.

Social

Con respecto a la vía jurisprudencial seguida una vez más en Argentina, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, en el año 1996, falla a favor de la colectividad. Se le concede la indemnización por daño moral colectivo a causa de una privación en el uso, goce y disfrute de un bien de dominio público municipal y establece lo siguiente:

> "*…si se parte del concepto de daño sufrido colectivamente como lesión a un bien público o colectivo, atendiendo a la naturaleza extra-patrimonial y colectiva de ese bien agraviado, como si se centra el enfoque en es el enfoque en el estado espiritual disvalioso que recae en la esfera social de una categoría de sujeto-los habitantes de dicha comunidad que disfrutaban del bien-por la afectación a una obra de patrimonio cultural local, que ostenta protección constitucional…"*[55].

Desde un comienzo, parece irreal la existencia de un daño social moral indirecto, por cuanto suele ser una figura asociada a un ser humano vinculada con la moralidad, sino que también resulta difícil de comprender la existencia de un reconocimiento aún más específico como lo es a nivel moral indirecto. Sin embargo, como se extrajo del segmento anterior, a nivel internacional el daño social general ya es más que reconocido, así las cosas, Argentina, de modo vanguardista, profundiza en la obtención de un aspecto más específico como lo es la consideración del individuo en su esfera personal afectada colateralmente (su psiquis o salud física), siendo este a su vez parte de una colectividad menoscabada por el mismo factor dañoso en niveles independientes.

Ahora bien, continuando en la búsqueda de especificidad de un daño tan colectivo, pero a su vez tan especifico a la hora del reclamo, surge más allá de un aspecto ambiental típico, una gama de daño político. Que si bien es cierto en ambos daños

[55] Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul. 1996. Municipalidad de Tandil y otros. 22 de octubre.

se reconoce la afectación del individuo perteneciente a la colectividad lo cierto del caso es que el hecho dañoso proviene de un “delito” distinto conllevando a un reconocimiento moral social indirecto indemnizable.

En razón de ello, sin quedarse atrás, las sentencias en el ámbito penal han establecido a su vez algún parámetro de reconocimiento sobre esta gama política. Sin embargo, cabe destacar que son aún pocos los votos referentes a dichos daños en estudio, por lo que se pretende comenzar a abrir el trecho para mayor investigación futura.

Es así como en el año 2003, Sala Tercera emite la siguiente resolución de la cual es posible interpretar que el daño social en este caso es un daño al interés colectivo o difuso, los cuales no son tan solo un criterio de legitimación (Artículo 10 Del Código Procesal Contencioso Administrativo Inciso 1, Acápite C[56]), sino también una situación jurídica sustancial que permite indemnizar la lesión no solo a un interés legítimo individual

> *"V.- [...] El artículo 38 del Código Procesal Penal otorga a la Procuraduría General de la República la potestad exclusiva de intervenir en el proceso penal para ejercer la acción civil por daño social. Para ello, le permite reclamar el resarcimiento respectivo por hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos. Lo que sucede en esta causa es que no se está ante ninguno de esos dos tipos de interés. El colectivo se refiere al que es propio de un grupo que se une, de hecho, o de derecho, en procura de perseguir un fin específico. En cambio, el difuso atañe al individuo por el simple hecho de ser integrante de la sociedad y le permite reclamar por algo que no afecta a un sujeto determinado, de modo que no puede establecerse un titular del derecho al resarcimiento, sino que es sufrido por la generalidad de individuos con la misma intensidad. Ninguno de esos supuestos se da en el presente caso, pues ni los migrantes han formado un grupo, ni la afectación es sufrida por una generalidad de personas. Los migrantes sufrieron cada uno de ellos una afectación de su patrimonio, la cual puede medirse monetariamente. Además, quienes pagaron a*

[56] **1)** Estarán legitimados para demandar:
(…)
c) Quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos.

FUNDEHCA eran individualizables y nunca formaron un grupo en persecución de un fin en particular. Así, no se estaba ante los supuestos del artículo 38 del Código Procesal Penal, sino más bien ante gran cantidad de intereses individuales, de modo que cada titular es quien debe (por sí o, si se hubiera hecho en el momento oportuno, mediante delegación en el Ministerio Público) reclamar la indemnización. Por lo expuesto, estima esta Sala que resulta conforme a Derecho la decisión del a quo de rechazar la legitimación de la Procuraduría General de la República para sustituir a los migrantes como actores civiles por los dineros pagados a FUNDEHCA."

Ahora bien, continuando en la línea del daño social en el año 2004 el Tribunal Penal de San José *en la sentencia n.° 341-*2004, del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, nos presenta un aspecto a considerar más allá del interés difuso o daño al medio ambiente, y por lo tanto se estableció la responsabilidad por parte de la Administración en ocasión de las actuaciones de sus funcionarios que afecten al colectivo e indirectamente a los sujetos de modo individual pertenecientes al conjunto afectado:

"… De acuerdo a estudios que se han hecho sobre el impacto en las naciones de la corrupción, se ha establecido que en aquellos lugares donde la corrupción es alta, la inversión desciende hasta un cinco por cientos como mínimo, de manera tal que la tasa de crecimiento económico se reduce en medio punto porcentual, produce el despilfarro debilitándose la economía y la confianza del público en las instituciones, socavándose las instituciones y redistribuyéndose la riqueza y el poder en forma injusta, poniéndose en marcha procesos de aprendizaje que van creando una cultura corrupta, de manera tal que se viene a distorsionar la realidad y se ven como legítimas conductas que no lo son. El artículo 38 del Código Procesal Penal otorga a la Procuraduría General de República la potestad exclusiva de intervenir en el proceso penal para ejercer la acción civil por daño social, para ello puede reclamar el resarcimiento respectivo por hechos punibles que afecten los intereses colectivos y difusos como en éste caso. (…) Ciertamente, existe la posibilidad de que los hechos que hoy se juzgan pudieran dar lugar al surgimiento de un daño social en virtud del desprestigio internacional que pudo haber sufrido nuestro país a raíz de las conductas llevadas a cabo por parte de funcionarios." (el subrayado no es del original)

El aspecto más importante por destacar del extracto anterior es un nuevo reconocimiento de daño social, llevado a nivel internacional. En donde un acto

corrupto que produzca desprestigio a un país, se reconoce como una falta hacia la Nación, sin embargo cavando más profundo, si bien es cierto un país se está viendo afectado a nivel de "imagen" frente al resto del mundo, la colectividad que conforma dicho país, a su vez se encuentra perjudicada indirectamente, tanto a nivel económico como turístico, entre otros, abriendo así una oportunidad de reconocimiento de daño social por la consumación de actos corruptos que lleven al decaimiento de un país y consecuentemente a su población.

De la mano con esto, bien se puede ver reflejado a nivel jurisprudencial, el Tribunal Penal de Hacienda en su voto 370 del año 2009, extrae la constitución del daño social por medio de un hecho delictivo, principalmente dentro de altos rangos, que provoca la intervención de la Procuraduría General en representación a nivel país como colectividad para un daño social moral. Sin embargo, viendo más allá el voto, que refleja la existencia de un daño social como una colectividad conjunta, es posible enlazarlo con el voto supra citado para lograr un análisis más profundo que permita el reconocimiento de un daño social indirecto por medio de los individuos que dicha colectividad que hoy en día si se encuentra respaldada a nivel jurisprudencial como se expone.

> *"…Motivos por los cuales se ha estimado en esta sentencia, que el efecto nocivo que tiene en la economía nacional, el pago de la comisión ilícita, financiada con fondos provenientes del empréstito concesional otorgado por el Gobierno finlandés,* ***constituye un daño social****, cuyo titular es la colectividad nacional en su conjunto, representada, por la Procuraduría General de la República..."*[57]

Así como la resolución 167 del año 2011 de este mismo Tribunal en el cual deja en claro que este tipo de daño que se detona por la actuación corrupta de un funcionario, extrae un factor subjetivo importante para la valoración a la hora de considerar la existencia del daño social moral como tal ya que señala tajantemente que el delito cometido debe provenir específicamente de un ***funcionario de alto rango***, ya que no existiría un impacto significativo si

[57] Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial. 2009. Voto 370. 5 de octubre.

proviniera de un funcionario de menor nivel jerárquico por el tipo de injerencia que pueda provocar este.

> *"Contrariamente dada su participación delictiva desde el primer Poder de la República,* ***así como el grave daño social ocasionado*** *y el significativo monto percibido a título de dádiva, bajo ninguna circunstancia se estima merecedor de su concesión.(…)*
>
> *De manera que,* ***en la producción del daño social*** *y lesión al bien jurídico, el mayor aporte fue de Valverde Acosta pues actúa siguiendo un esquema previamente establecido con ese fin (…).*
>
> *La condición de Presidente de la República no es cualquier condición personal, (…)* ***pues no genera el mismo daño social****, por ejemplo, que un humilde funcionario público del mínimo escalafón sea condenado por este delito a que lo sea quien ocupa la cima jerárquica de toda la Administración Pública."*[58]

Es por esto por lo que, si utilizamos los factores básicos, esbozados en el primer capítulo del presente proyecto, para determinar si existe o no un daño social indirecto, es posible evidenciar, primero que los sujetos, se encuentran vinculados indirectamente al hecho dañoso principal como lo es el individuo dentro de la colectividad representada afectada por un alto rango[59], como segundo aspecto existe una relación de hecho y consecuencia reflejado en el hecho ilícito y la deshonra como ciudadano de la nación, y por último subsiste un daño, es decir en este caso la certeza de la existencia de una afectación constatable, como se puede corroborar en la comisión del delito de corrupción.

Como aspecto no menos importante en el presente apartado, se desprende una vez más por vía jurisprudencial el reconocimiento del daño social, mediante la aplicación interpretativa de las normas que se señalan en el voto 71 del año 2013 del Tribunal Penal de Hacienda en cuanto al canon 1045 del Código Civil como deber de reparación básico así como los articulados 103, 122 al 128 del Código Penal

[58] Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial. 2011. Voto 167. SF

[59] Ver sentencia del Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial. 2013. Voto 548. 14 de noviembre, se relaciona con el tópico.

permitiendo enlazar dicha información con la sección anterior propia de la parte normativa del presente proyecto.

> ***"VII.- SOBRE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA Y EXCEPCIONES:***
>
> *Para que surja la responsabilidad civil en virtud de un hecho ilícito se requiere que exista un resultado dañoso a un tercero, que el mismo sea atribuible al sujeto y que exista una relación causal entre uno y otro. Desde esa óptica, con fundamento en el artículo 1045 del Código Civil que establece que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, ocasiona a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios, lo mismo que el artículo 103 del Código Penal sobre la obligación civil de reparar los daños y perjuicios provocados con la realización de un hecho punible y los numerales 122, 124, 125, 126 y 128 del Código Penal 1941, procede la fijación de responsabilidad civil de PJ y DC, quienes con su actuar provocaron una lesión a la buena imagen de los funcionarios públicos, particularmente a los del Ministerio de Obras Públicas y Transportes – Consejo de Seguridad Vial, (COSEVI), garantes de la seguridad vial y el cumplimiento de las leyes de tránsito, ocasionando en el ciudadano una pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones públicas…"*[60]

A modo de resumen es claro que la existencia de un daño social moral indirecto es concebible desde algunos puntos de vista a la hora de ser indemnizable. Por lo que recapitulando, desde el aspecto subjetivo debe valorarse quien es el individuo a la hora de la comisión del daño, en este caso un alto funcionario si hablamos de una afectación de gama política, en cuanto al punto objetivo, es aquel deber de corroborar la existencia de un daño concreto y evidente y por último un nexo de causalidad entre la víctima indirectamente afectada, quien pertenece a la colectividad dañada, como primer sujeto indemnizable, pero a su vez una víctima resarcible como un sujeto individual afectado indirectamente por ser parte de dicha esfera.

[60] Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial. 2013. Voto 71. SF

Capítulo III. Guía de aspectos básicos procesales y sustanciales del daño moral indirecto.

LEGITIMACIÓN.

Uno de los aspectos más debatidos en este tema, es lo relativo a la legitimación activa. El cuestionamiento central es si la víctima directa puede reclamar por y para los lesionados indirectos. O si, por el contrario, deben acudir los lesionados indirectos como únicos legitimados. En este aspecto nos inclinamos por una legitimación abierta, en la medida en que, sin perjuicio del reclamo directo de quien sufre un daño (ya se trate de víctima primaria o derivada), puede haber una legitimación vicaria del lesionado originario para reclamar las que fueron ocasionadas al tercero, máxime si se trata de familiares o dependientes suyos.

No cabe duda, de que dicha legitimación (vicaria) opera por derecho en tratándose de menores o incapaces, para asignarla a su tutor legal. Fuera de allí, debemos reconocer que resulta de difícil aplicación, salvo disposición legal expresa en ese sentido.

Lo anterior no debe confundirse con la titularidad (derecho) para la indemnización efectiva. En otras palabras, podrá reclamar el lesionado originario por quien fue tercero afectado, pero solo será este último el titular definitivo de la reparación dispuesta por el pronunciamiento firme y favorable.

Desde esta perspectiva el menor adquiere a tales efectos indemnizatorios la capacidad y la legitimación, tal y como lo dispone nuestra legislación positiva, no carente de lagunas, oscuridades y cuestionamientos. En este sentido, es preciso añadir que la prescripción para efectos de exigir los derechos a favor de menores comienza a contabilizarse a partir de su mayoría de edad (artículos 198 párrafo final reformado en el año 2012 en concordancia con los numerales 868 del Código Civil y 31 del Código Penal).

TIPO DE DAÑO.

Es este apartado se hará énfasis en los daños y/o los perjuicios que se le ocasionan a la tercera persona en su condición de víctima.

De más está decir que, pueden serlo de cualquier orden o naturaleza. Así parece natural aceptar que lo pueden ser de orden económico, como los perjuicios ocasionados por el abandono obligado de sus actividades. O bien, pueden irrumpir en el ámbito del daño moral subjetivo; así como también en el daño emergente, y desde luego cubrir la pérdida de oportunidad.

Hay que reconocer que las lesiones se manifiestan, sobre todo, en el espectro de los perjuicios, sin que sea dable, por supuesto, la exclusión de los daños, como ocurre con el emergente ocasionado por los gastos necesarios del tercero para el resguardo, los cuidados y la recuperación o tan solo el alivio de la víctima primaria. Es claro entonces que el indirecto por serlo, no excluye en modo alguno la lesión patrimonial, ni la moral, ni la cultural, financiera, social, e incluso corporal para supuestos singulares.

Frecuentes han sido los casos en que se ha reconocido el daño moral subjetivo a terceros en la jurisprudencia de la Sala Primera. Es este el caso del que se produce a la esposa, hijos o padres por el fallecimiento de un ascendiente, descendiente o pareja. De nuevo es preciso aclarar que, no se trata de la lesión moral que hubo de enfrentar el fallecido, sino del menoscabo moral propio, del suyo como tercera persona, no el de la víctima primaria, ya referidos páginas atrás.

Aquí se nuevo se hace imprescindible, diferenciar, ad initio, la lesión ocasionada al tercero como víctima, de aquella traslación indemnizatoria que recibe un tercero de aquello que correspondía a la víctima de base, ello ocurre ante el fallecimiento del lesionado directo, o bien, por la cesión de derechos de éste a un tercero. Así se presentan, a modo de ejemplo, las sumas dinerarias, subsidios, pensiones, o retribuciones periódicas a los supérstites. Pero en todo caso, ese tercero no aparece en la relación jurídica creada, como una víctima del hecho o acto productores de la

lesión, sino como simple beneficiario, de lo que en su momento debía ser otorgado a la única y exclusiva víctima.

También se ha extendido (y reconocido con frecuencia) el elemento objetivo del daño a terceros cuando se trata de la lesión ambiental. En este supuesto, la o las personas afectadas reciben una onda expansiva de tales daños y perjuicios, que se producen a unos bienes con incidencia directa en unos y otros. Incendio en áreas forestales; contaminación sónica y visual; contaminación de un río; o de un área marítima por contaminación (v.gr. por derrame de petróleo). Cabe advertir hasta la saciedad, del debido cuidado que en este aspecto habrá de tenerse, a fin de no confundir el daño que por el hecho generador de la lesión se le causa a una persona en calidad de co-víctima (como parte de una pluralidad de afectados); de aquel que, se le ocasiona a una persona (que figura como tercero), por efecto o consecuencia del que le fue ocasionado a la víctima primaria o principal; todo ello, conforme fue expuesto esquemáticamente ut supra.

En lo relativo al destinatario de la lesión (sujeto pasivo del daño, tercero), hay que decir que puede tratarse de persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjero, mayor o menor de edad. Y cubre también, sin lugar a duda, al tercero perjudicado individual o colectivo, como persona formalmente constituida, o bien, como grupo informal.

De allí que se pueda referir a un daño concreto o bien general, atendiendo, cabalmente al destinatario.

Ello implica, por fácil inferencia, la superación conceptual de daño indirecto individual, para dar paso al Daño Indirecto Supraindividual (dentro del que se ubica el mal llamado “social”).

MECANISMOS DE PRUEBA DEL DAÑO INDIRECTO.

Pareciera que el tipo de lesión sea que se trate de daños[61] o bien de perjuicios, en cualquiera de sus vertientes, están sujetos a los mecanismos de prueba ordinaria, no solo para demostrar su existencia sino, además, su vínculo causal con el hecho o conducta del que se derivan. Habrá de aplicarse en mecanismo en vigencia de la prueba dinámica, incluyendo las presunciones allí donde puedan ser establecidas, o en su caso, la flexibilización probatoria.

CUANTIFICACIÓN DE LA LESIÓN.

Problema diverso opera con la cuantificación de la lesión, esto por la característica propia de los daños y los perjuicios derivados, no de una acción directa del responsable, sino como reflejo de esta última. Ya se ha dicho que en gran medida serán representados por perjuicios o pérdida del chance, en que la prueba pericial jugará un papel determinante, en especial, la experticia de psicólogos y de actuarios matemáticos.

En este punto, la indexación jugará un papel importante a efecto de actualizar cualquier obligación dineraria nacida en calidad de indirecta.

PRESCRIPCIÓN DE DICHA RESPONSABILIDAD

Los plazos de prescripción para la lesión indirecta han de ser los mismos que aplican para el derecho de fondo aplicable la responsabilidad directa, v.gr.: diez años para la responsabilidad civil; cuatro para la responsabilidad de la Administración Pública; cinco para la responsabilidad indirecta nacida de contrato público, etc.

---

[61] OSSORIO SERRANO, JUAN MIGUEL. Lecciones de Derecho de daños. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2011.

No obstante, en cuanto al momento inicial para el cómputo del plazo, no parece razonable establecer la fecha a partir del conocimiento del hecho dañoso inicial o primario, pues la subsecuente lesión indirecta no surge casi nunca en forma inmediata. De esta forma, parece razonable admitir que el cómputo inicial de la prescripción por lesión indirecta debe fijarse a partir de que el tercero tenga conocimiento de su lesión. Esto nos lleva a una dificultad adicional para el evento en que la responsabilidad del lesionado directo hubiera prescrito. ¿Podría en tal caso reclamarse la responsabilidad nacida para con el tercero con posterioridad a la responsabilidad prescrita frente a la víctima inicial? En principio, con nuestra posición proclive a la protección de la víctima, nos inclinamos por el válido y vigente reclamo del tercero respecto de quien figura como responsable antecedente. Se trata, según hemos dicho, de supuestos vinculados, pero a su vez independientes.

Aspecto diverso opera con el daño indirecto continuado, entendido como aquél que perdura en el tiempo (comúnmente en forma periódica), pero que se reputa o atribuye a la lesión inicial u originaria causada a la víctima primaria. Tal es el caso de una lesión psicológica a un tercero mantenida en el tiempo a consecuencia de un daño producido a un ser querido (muerte, tetraplejía, discapacidad física, entre otros); o bien, el abandono prolongado o intermitente de su trabajo o estudio; o incluso, el deterioro físico gradual y constante de una madre entregada a su hijo permanentemente en cama por largos años.

En tal supuesto, es claro que la prescripción no inicia su cómputo sino hasta el cese de esa lesión indirecta. Y en este punto, a riesgo de herejía jurídica, estimamos que debe imponerse una responsabilidad con efecto retroactivo y nunca, o no solo, futuro (ex nunc) a la firmeza de la sentencia condenatoria.

COSA JUZGADA RESPECTO DEL LESIONADO DIRECTO.

Puede ocurrir que el lesionado directo haya acudido a Tribunales en busca de su reparación. En tal caso, el pronunciamiento favorable o estimatorio de sus pretensiones no produce cosa juzgada en favor del tercero) en contra del

responsable por tratarse de relaciones jurídicas correlacionadas, pero con algún grado de independencia. Se trataría de un asunto con sujetos y objeto diversos.

Cosa distinta ocurre cuando en la sentencia firme previa dictada para quien inicialmente fue lesionado, se declara improcedente la pretensión, ya sea por inexistencia de un criterio de imputación, de daño o de nexo causal, pues ello impide, por mayoría de razón la responsabilidad por un efecto rebote respeto de un tercero.

Diverso es el supuesto de que no se hubiere ejercido acción alguna del lesionado directo contra el responsable (o hubiera prescrito, según vimos antes), pues en tal evento, nada obsta para en el proceso del tercero se discuta sobre la acción u omisión dañosa del supuesto responsable, siquiera sea para la indemnización del tercero.

EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD INDIRECTA.

En este caso, los criterios eximentes se centrarán, no ya en aspectos concretos de exculpación, sino derivados del nexo de causalidad que opera entre la lesión primaria producida a la víctima originaria, respecto de la lesión que por consecuencia de aquella (secundaria o derivada) se produce a una o unas terceras personas. Hoy tendríamos que referir como causas de exoneración de responsabilidad en este caso, a la fuerza mayor, culpa de la propia víctima, o bien, hecho de tercero. Y, desde luego, cuando no se trate de la Administración Pública como responsable, al caso fortuito. Para la procedencia de estas exoneraciones de la responsabilidad, habrá de comprobarse la ruptura del nexo causal entre la lesión ocasionada a la víctima primaria o inicial, y el daño ocasionado al que podríamos llamar, secundario o indirecto.

CONCLUSIONES

7. En definitiva, se puede afirmar que la hipótesis originaria de este trabajo final de investigación no es plenamente cierta. Esto, por cuanto la figura de la responsabilidad por lesión o daño indirecto no está expresamente regulada en el régimen jurídico costarricense. Sin embargo, lo anterior no impide que pueda extraerse sin problema como producto de una adecuada y válida interpretación de las normas vigentes, e incluso, por extrapolación de los pocos preceptos legales que ello hace referencia en determinados ámbitos sectoriales.
8. De igual manera, y en referencia con la hipótesis expuesta, hay que añadir que en el campo jurisprudencial se han emitido numerosos pronunciamientos reconociendo la debida reparación patrimonial para aquellos terceros lesionados por consecuencia o reflejo de la lesión antecedente de la víctima principal.
9. No obstante, aún con todo ello, el escaso o ausente tratamiento a todo nivel sobre este tema, revela la pertinencia de algunos ajustes normativos para el fortalecimiento y la adecuada definición de la figura, acompañados de un serio desarrollo jurisprudencial y doctrinal en nuestro medio.

A continuación, se exponen algunas de las principales conclusiones jurídico técnicas obtenidas del proyecto de investigación que materializan los objetivos inicialmente propuestos:

10. La figura de la lesión indirecta se presenta como un fenómeno en el cual se extiende la lesión como elemento objetivo de la responsabilidad patrimonial a un tercero, distinto o ajeno a la afectación que haya recibido la víctima original, o primaria o principal.
11. Lo anterior provoca la responsabilidad del agente productor de la lesión, no solo respecto de la víctima inicial, sino, además, ante ese tercero lesionado.
12. Se trata de una expansión del daño y de los sujetos con derecho a indemnización por hecho propio del responsable. Ese mismo hecho provoca

lesiones a diversas personas de manera sucesiva, directa para la primera, indirecta para la segunda.

13. Lo anterior excluye y la diferencia de la responsabilidad por hecho ajeno, en que se extiende no el daño ni la víctima, sino los sujetos responsables, pues en esta aparece un tercero obligado a reparar por la extensión no del daño, sino del criterio de imputación utilizable (dolo, culpa, ilicitud, etc.), denominada tradicionalmente culpa in eligendo o culpa in vigilando.

14. En la responsabilidad por lesión indirecta se mantiene la relación de causalidad eficiente y determinante. Tanto así que, bajo la teoría de la supresión hipotética, si no se presenta la lesión originaria, no existiría tampoco la indirecta. En la figura de estudio un nexo causal de segundo nivel, que podemos denominar como consecuencial o de rebote.

15. La víctima indirecta tiene derecho a la reparación plena a cualquier de sus derechos o intereses lesionados, en calidad de daños, y también, perjuicios; cualquiera sea su naturaleza (patrimoniales, corporales, morales, psicológicos, emergentes, pérdida de oportunidad, etc.)

16. Todo lo anterior cubre tanto las lesiones indirectas “familiares” (que preferimos denominar concretas o individuales), como las provocadas a intereses colectivos o difusos, mal llamados “sociales”.

17. En las lesiones indirectas (mal llamadas “familiares”) es difícil establecer el nivel de vínculo necesario entre la víctima originaria o la subsecuente o indirecta para provocar el derecho indemnizatorio exigible. Esto así, porque puede superar el frecuente vínculo consanguíneo o por afinidad que frecuentemente se presenta en estos casos. La dependencia y/o cercanía serán factores que tomar muy en cuenta para estos asuntos. Todo ello nos lleva a cuestionar la posibilidad de concretar un vínculo especifico como elemento necesario para este tipo de responsabilidad. ¿Es acaso imprescindible un vínculo familiar o basta cualquier otro de tipo sentimental, amistoso o de mera solidaridad humana? Esto deja abierta una discusión por abordar de manera amplia y profunda tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial en el transcurso de los próximos años.

18. Los “daños sociales”, solo están expresamente previstos en nuestro ordenamiento jurídico positivo, para la materia penal. Y, pese a su aplicación práctica en nuestra jurisprudencia nacional, existen aún múltiples vacíos en lo relativo a su alcance o contenido, al verdadero nexo causal y a su obligada demostración. La figura del “daño social” sigue siendo imprecisa, de allí que resulta criticable la condena a indemnizaciones con tan débil noción conceptual y escasos elementos probatorios. Desde este punto de vista se hace imprescindible un tratamiento amplio, serio y profundo sobre esta temática.

19. En la doctrina nacional, apenas y se menciona la figura bajo estudio, por lo que aún está pendiente un amplio desarrollo de sus diversos tópicos, profundizando en legitimación, en la causalidad, en la determinación del daño y sus variables probatorias.

20. En definitiva, en la esfera jurídico-positiva nacional, la figura de la lesión indirecta no está excluida ni prohibida. En nuestro criterio, con muy pocas salvedades, la normativa general permite, vía interpretación, incorporar la responsabilidad por lesión indirecta. Cabe remarcar aquí, que en el ámbito penal se ha logrado una regulación expresa, tanto para la lesión indirecta individual, como para la colectiva (denominada “daño social”). Pero aún con todo, el reconocimiento que ello merece, resulta normas destinadas a supuestos específicos y por tanto, de cobertura parcial.

    Debido a todo ello, nos parece necesario explicitar la figura para todos los ámbitos a través de la modificación legal de unas pocas normas.

21. En el ámbito jurisprudencial, la responsabilidad por lesión indirecta a terceros se ha venido aplicando para casos específicos (sobre todo penales), pero más que con plena conciencia de ello y del dominio pleno de la figura, se ha reconocido la reparación por mero sentido común, instinto jurídico y justicia de las personas juzgadoras.

RECOMENDACIONES

En el apartado de recomendaciones, se suele acudir de primera mano al recurso de la reforma legal, obviando con ello medidas de mayor inmediatez, que, en forma conjunta con la variación de normas legales, dan mayor solidez y eficacia a una reforma integral.

Desde esa perspectiva, procedemos a realizar las siguientes recomendaciones, en modo alguno excluyentes y ni siquiera sucesivas.

1. Aunque ya se ha dicho que la responsabilidad patrimonial por daño indirecto o reflejo no es novedosa en la legislación ni en la práctica, lo cierto es que se ha abordado de manera muy primaria, o si se quiere rudimentaria, lo cual exige que en la actualidad se aborde con un mayor rigor científico- doctrinal, estableciendo, de manera detallada, su ámbito de cobertura y sus alcances; sus requisitos y las diversas consecuencias procesales.

2. A partir de allí, se debe avanzar en una formación de los operadores jurídicos sobre la figura (si se quiere desde las etapas tempranas de formación profesional), y, en especial, actualizar (cuando no formar) a las personas juzgadoras. Con ello, aún con la legislación vigente, se podrá alcanzar una mejor recepción de la figura a nivel jurisdiccional, y un abordaje más preciso sobre el tema por vía jurisprudencial.

3. Aunque en la mayoría de las normas jurídicas vigentes no se impide la reparación del daño indirecto o reflejo, es conveniente establecer su procedencia a nivel legal, con algunos aspectos adicionales que despejen dudas o confusiones.

En virtud de ello, nos permitimos proponer la reforma legal de al menos dos artículos, a saber, el 704 del Código Civil y el 193 de la Ley General de la Administración Pública, todo ello, en los siguientes términos:

Artículo 704 del Código Civil.

En la indemnización de daños y perjuicios se comprenderán los que, como consecuencia de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado, o deban necesariamente causarse, a una o varias personas, así como a terceros en su condición individual o supraindividual.

Artículo 193 de la Ley General de la Administración Pública.

> 1. La Administración Pública, el Estado o cualquier persona privada, en el ejercicio de actividad administrativa, legislativa, judicial, o bien, privada, serán responsables plenamente por la lesión a derechos subjetivos o a intereses legítimos individuales o supraindividuales, ya sean públicos o privados.
>
> 2. La reparación indicada comprenderá, no solo los daños y perjuicios que se hubieren causado a la víctima directa, sino también los irrogados a terceros, ya sea en su condición individual o supraindividual.
>
> 3.- También cabe reparación a los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos, por la lesión sufrida a consecuencia de la pérdida de oportunidad.
>
> 4.- El régimen de responsabilidad patrimonial establecido en este artículo, se regirá por las reglas jurídicas previstas en los capítulos primero y segundo del presente Título Sétimo, y supletoriamente, por las normas del derecho privado.

4. Por su parte, a nivel jurisprudencial, es claro que, a nivel nacional, el tema de daño moral social y familiar se comienza a esbozar a través de la jurisprudencia lentamente, sin embargo, es necesario realizar un refuerzo que permita un análisis con mayor profundidad del tema. Esto por cuanto, el daño social se encuentra respaldado, mas no, de manera detallada, como la sociedad lo comienza a exigir a través de sus ramificaciones de daño, que no bastan ser cubiertas por medio de una figura general que se presta para ambigüedades en tanto puede o no reconocerse según el caso y el juicio de quien resuelve.

BIBLIOGRAFÍA

Doctrina:

- AA. VV. Derecho de daños, 1ª ed. La Rocca, 1989, Buenos Aires
- Boffi Boggero. L. Tratado de las Obligaciones. Astrea. 1985. Buenos Aires.
- CASAHUGA, A., Fundamentos normativos de la acción y organización social, Ariel-Economía, 1985, Madrid.
- CHABAS, F., Derecho a reparación de las víctimas de la circulación, en: Derecho de Daños, 1ª ed. La Rocca, 1989, Buenos Aires.
- DEPALMA J. Los nuevos daños soluciones modernas de reparación 2. Editorial Hammurabi SRL. Buenos Aires, 2000. Argentina. Pág. 171
- GONZÁLEZ J. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Editorial Civitas S.A. 1996. Madrid, España.
- MORELLO, A., La defensa de los intereses difusos, Rev J.A., 1981.
- MORENO MARTINEZ. J. Daños Indirectos En Familiares Y Terceros Por Causa De Lesiones. ARANZADI, 2011, España.
- NAVEIRA ZARRA, MAITA MARÍA. «Clases de daños resarcibles». El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual. VLex, 2006
- OSSORIO SERRANO, JUAN MIGUEL. Lecciones de Derecho de daños. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2011.
- ORGAZ, ALFREDO: «El Daño Resarcible», Ediciones Depalma,1967, Buenos Aires, páginas 188-189.
- PEÑA MARIO. Daño Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente. Investigaciones Jurídicas S.A. 2011. Costa Rica.
- PIETRO MOLINERO, R. J., El sistema de compensación de daños personales de Nueva Zelanda, (Mimeo).
- QUIROGA LAVIÉ, H., Los derechos públicos subjetivos y la participación social. Depalma, 1985, Buenos Aires.

- RIVERO JUAN MARCOS. 1999. Responsabilidad Civil Volumen I. Ediciones Jurídicas Areté. San José, Costa Rica. Pág 98.
- RIVERO JUAN MARCOS. Responsabilidad Civil Tomo II. Ediciones Jurídicas Areté. 2001. San José Costa Rica. Pág 111
- ROCA, ENCARNA. Derecho de daños. Textos y materiales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.
- SANTOS BALLESTEROS, J., Instituciones de responsabilidad civil, 2ª ed., Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, 2006.
- Torrealba Navas F, Responsabilidad Civil, Editorial Juricentro, Costa Rica, 2011.
- TRIGO REPRESAS, F. A. y LÓPEZ MESA, M. J., Tratado de la responsabilidad civil, I, 1ª ed. La Ley, 2004, Buenos Aires.
- VAN BOVEN, TH., «Reparations. A Requirement of Justice», op. cit., p. 661; y, van Dijk, P.; van Hoof, F.; van Rijn, A., y Zwaak, L. (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4.ª ed., Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2006, pp. 245-251.
- VINEY, G., Traité de Droit Civil. Les obligations. La responsabilité, 1982, París.
- ZAVALA DE GONZÁLEZ, M., Daño colectivo, en Derecho de Daños, 1ª ed. 1989, La Rocca Buenos Aires.
- ZANNONI A. EDUARDO. El daño en la responsabilidad civil. Editorial Astrea. 1987. Buenos Aires.
- ZAVALA DE GONZÁLEZ. Matilde. Tratado de Daños de las Personas. Resarcimiento del daño moral. Editorial Astrea 2009. Buenos Aires.
- ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde en Trigo Represas, Félix A., López Mesa, Marcelo J., *Tratado De La Responsabilidad Civil, Tomo III*, Ed. La Ley, 1º Ed., Buenos Aires, 2004, p. 59.

Normativa:

- Artículo 38 del Código Procesal Penal
- Artículos 41 y 50 de la Constitución Política
- Artículo 1045 del Código Civil

Jurisprudencia:

1. Nacional:

    - Sala de Casación Civil. 1942. 7 de mayo.
    - Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 1973. Voto 551. 21 de agosto.
    - Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 1975. 7 de mayo.
    - Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 1987. Voto 49. 22 de mayo.
    - Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 1988. Voto 114. 22 de abril.
    - Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 1990. Voto 263. 22 de agosto.
    - Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 1991. Voto 153. 5 de abril.
    - Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 1991. Voto 474-F. 13 de setiembre.
    - Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 2003. Voto 176. 20 de marzo.
    - Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial. 2009. Voto 370. 5 de octubre.
    - Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial. 2011. Voto 167. SF

- Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial. 2013. Voto 71. SF.
- Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial. 2013. Voto 548. 14 de noviembre.
- Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 2019. Voto 342. 3 de abril.
- Tribunal Penal II Circuito Judicial de San José. 2023. Voto 157.

2. Internacional

- Sala de Casación Civil. Emilio Ordoñez Mutis y Lucila Ordoñez Barco contra el Departamento de Santander.
- Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul. 1996. Municipalidad de Tandil y otros. 22 de octubre.

Tesis:

Aguirre Garabito. A. Sibaja López. I. 2010. Lineamientos Para La Comprensión Del Daño Social Y Sus Posibles Aplicaciones En El Derecho Costarricense. Licenciatura. Universidad De Costa Rica.

Artículos:

- Los daños colectivos - prospectiva general (en prensa).
- Los daños colectivos y la reparación,1ª ed. Universidad, 1993, Buenos Aires.
- Daño Social, Daño Moral Colectivo Y Daños Punitivos. Delimitaciones Y Alcances En Materia Ambiental. M.Sc. Mario Peña Chacón. 2012.

- La Inclusión De Los Daños Colectivos En El Derecho De Daños: De Las Fronteras Individuales A La Realidad De La Colectividad. Lidia María Garrido-Cordobera, Vniversitas, no.118, 2009, Bogotá.
- El Daño Social: Su Conceptualización Y Posibles Aplicaciones. Lic.Ana Lucía Aguirre Garabito y Licda. Irina Sibaja López. Revista Judicial, Costa Rica, Nº 101, 2011.